

임금의 개념에 비추어 본 포괄임금약정

박 은 정



법제처

Ministry of Government Legislation

www.kci.go.kr

임금의 개념에 비추어 본 포괄임금약정

박 은 정 (EunJeong Park)
한국방송통신대학교 법학과 교수

논문접수 : 2025. 8. 4.

심사개시: 2025. 8. 5.

게재확정: 2025. 8. 26.

목 차

I. 서론

II. 임금의 이해

1. 학설과 판례
2. 근로의 대가로서 임금
3. 임금의 사전확정 가능성

III. 임금과 포괄임금약정

1. 포괄임금약정의 의미와 종류
2. 정액급제 포괄임금약정
3. 정액수당제 포괄임금약정

IV. 과·오지급된 임금과 포괄임금약정

1. 포괄임금약정 무효에 따른 임금계산의 문제
2. 무효인 퇴직금 분할약정과 지급된 퇴직금의 성격에 관한 판례와 학설
3. 포괄임금약정 하에서 과·오지급된 임금과 근로자의 반환의무

V. 정리하며

www.kci.go.kr

국문초록

임금은 근로의 대가로서 사용자로부터 지급되는 금품이며, 지급의무성, 근로대응성, 정기성, 계속성 등은 보조적 기준일 뿐, 본질적으로 근로계약에 따른 대가성이 핵심이다. 임금 총액은 근로의 양·질, 근무실적, 근로시간 등 사후적 요소에 따라 변동되므로, 임금 총액의 사전확정은 원칙적으로 이루어지기 어렵다. 그리고 이러한 범위에서 정액급제 포괄임금약정은 근로시간을 전제로 산정하게 되어 있는 근로기준법 규정은 적용 자체를 형해화시키는 것일 뿐만 아니라, 근로의 대가인 임금의 의미에 비추어서도 성립할 수 없다.

포괄임금약정 가운데 정액수당제 포괄임금약정의 경우 야간근로수당은 언제 근로가 이루어지는가라는 문제로서 야간근로를 통해 침해될 수 있는 근로자의 건강권과 휴식권에 대한 보상적 임금이라는 점, 휴일근로수당은 근로자의 휴식권과 관련된 보상적 임금이고, 그 계산은 근로시간에 비례하면서 그것이 1일 8시간을 초과하였는지 여부에 따라 계산방법이 달라져야 한다는 점에서 포괄임금약정이 포함될 수 없다. 판례는 연차유급휴가수당도 포괄임금약정에 포함될 수 있다고 보고 있는데, 이러한 해석은 연장·야간·휴일근로수당에 대한 오해보다 더 큰 오해가 발생한 결과이다. 시간외근로수당 등의 시간단위 법정수당에 대한 포괄임금약정 또한 연장근로시간을 미리 정해두지 않고 사용자의 사정에 따라 근로시간을 유동적으로 활용할 수 있도록 하겠다는 의미로 해석될 여지가 있는 바, 근로시간을 미리 정해 근로자들의 생활상 편의를 도모하고자 하는 근로기준법상 근로시간제도의 취지를 위반하는 것이라고 보지 않을 수 없다.

마지막으로, 포괄임금약정이 무효로 판단되는 경우 실제 근로시간에 따라 법정수당을 재산정해야 한다. 이때 이미 지급된 임금이 법정수당을 초과하면 반환 문제가, 미달하면 추가지급 문제가 발생할 수 있다. 그런데 과다하게 지급된 임금이 문제되는 경우라도 포괄임금약정의 무효에 따라 이미 근로자의 근로시간에 대하여 이미 지급된 임금으로 수렴되어야 한다.

※ 주제어: 임금, 임금의 개념, 임금의 사전확정가능성, 포괄임금약정, 정액급제, 정액수당제

I. 서론

임금이란 무엇인가? 어떻게 지급되어야 하는가? 단순한 질문이기도 하고, 이미 “근로의 대가” 사용자가 지급하는 금품이라는 정의와 임금지급의 방법이 근로기준법에 명시되어 있기도 함에도 이 질문을 하는 것은 포괄임금약정을 염두에 두고 있다. 포괄임금약정에 대해서는 근래 입법적으로 이를 금지하자는 의견도 많고, 실제 포괄임금약정을 금지하는 내용의 근로기준법 개정안도 다수 발의되어 있다.¹⁾ 이들 근로기준법 개정안은 포괄임금제가 장시간 근로 관행을 고착시키고, 법정수당 미지급·임금체불 등 노동권 침해의 원인으로 지적되며 사회적 비판이 고조되고 있는 환경을 반영한다.

포괄임금약정이란 “사용자와 근로자가 기본임금을 미리 정하지 않은 채 법정수당까지 포함된 금액을 월 급여액이나 일당임금으로 정하거나 기본임금을 미리 정하면서도 법정 제수당을 구분하지 않은 채 일정액을 법정 제수당으로 정하여 이를 근로시간 수와 관계없이 지급하는 것”에 대한 합의이다.²⁾ 이 정의에 따르면 1임금지급기에 지급되어야 할 임금 총액 또는 일부를 사전에 확정해 두는 것이 포괄임금약정이고, 이러한 약정의 가능성을 일정한 요건 하에서 제한적으로나마 포괄임금약정은 유효하다는 것이 현재 판례의 입장이다. 물론 현재 언제나 포괄임금약정이 유효하다고 해석되는 것은 아니다. 판례에 따르면, 포괄임금약정이 유효하게 성립하기 위해서는 ① 근로시간, 근로형태와 업무의 성질을 고려할 때 근로시간의 산정이 어려울 것, ② 포괄임금제에 의한 임금 지급계약을 체결하더라도 그것이 달리 근로자에게 불이익이 없을 것, ③ 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 것이 요구된다. 그래서 포괄임금약정이 명시되지 않았음에도 “근로형태의 특수성으로 인하여 실제 근로시간을 정확하게 산정하는 것이 곤란하거나 일정한 연장·야간·휴일근로가 예상되는 경우 등 실질적인 필요성이 인정될 뿐 아니라, 근로시간, 정하여진 임금의 형태나 수준 등 제반 사정에 비추어 사용자와 근로자 사이에 그 정액의 월급여액이나 일당임금 외에 추가로 어떠한 수당도 지급하지 않기로 하거나 특정한 수당을 지급하지 않기로 하는 합의가 있었다고 객관적으로 인정되는 경우”에는 묵시적 합의에 의한 포괄임금약정 성립을 인정할 수 있다고 보기도 한다.³⁾

1) 22대 국회 기준, 의안번호 2200073(박해철 의원 대표발의 근로기준법 일부개정법률안), 의안번호 2202812(박홍배 의원 대표발의 근로기준법 일부개정법률안), 의안번호 2203882(박주민 의원 대표발의 근로기준법 일부개정법률안), 의안번호 2205236(이용우 의원 대표발의 근로기준법 일부개정법률안), 의안번호 2205237(정혜경 의원 대표발의 근로기준법 일부개정법률안) 등.

2) 대법원 2024. 2. 8. 선고 2018다206899, 2018다206905(병합), 2018다206912(병합) 판결.

위와 같은 해석에 따라 근로기준법상 사용자에게 지급 의무가 있는 각종 법정수당 등을 포함하여 임금을 포괄적으로 약정하는 것(이하, ‘포괄임금약정’)이 제한적으로나마 받아들여지고 있는 현재, 포괄임금약정이 성립할 수 있는지, 있다면 그 근거는 어디에 있는지, 포괄임금약정에서 포괄하고 있는(혹은 포괄할 수 있는) 임금은 무엇인지, 포괄임금약정이 있는 경우 근로자는 그 약정에 따라 별도의 각종 법정수당 등을 청구할 권리는 없다고 보아야 하는지 등에 대한 의문이 있다.

이 글은 위 의문을 풀어 나가 보기 위해 우선 임금을 이해하면서 포괄임금약정을 다시 해석해 보고자 한다. 특히 이하에서는 임금의 사전확정 가능성을 확인해보고자 한다. 포괄임금약정이 가능하다는 것은, 근로기준법상 근로의 대가인 임금이 어떠한 사유에 의해 사전에 확정될 수 있음을 전제하는 것이기 때문이다. 한편, 포괄임금약정이 무효인 경우 과·오지급된 임금의 반환 등이 문제될 수 있는 바, 보론적으로 이 문제에 대해서도 함께 살펴보고자 한다.

II. 임금의 이해

1. 학설과 판례

근로기준법 제2조 제1항 제5호는 “임금”이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품을 말한다.”라고 정의하고 있다. 임금은 근로기준법 등 여러 근로보호법제가 작동하는 기준으로 기능하여, 해고예고수당, 연차유급휴가수당, 시간외 근로수당, 휴업수당, 평균임금과 통상임금, 퇴직금, 사회보험료 납부액 등의 기초를 이룬다.

한때 임금을 교환적 부분과 생활보장적 부분으로 구분해 근로의 제공이 이루어지지 않은 동안에도 생활보장적 임금은 지급되어야 한다는 임금2분설이 있기도 하였지만,⁴⁾ 현재는 최소한 임금2분설에 기초해 임금을 이해하는 견해는 없는 것으로 보인다. 편의상 이미 기존의 선행 연구를 정리하고 있는 선행 연구에 기초해 살펴보면,⁵⁾ 우리나라에서 학자들은

3) 대법원 2016. 10. 13. 선고 2016도1060 판결, 대법원 2024. 2. 8. 선고 2018다206899 판결 등.

4) 대법원 1992. 3. 27. 선고 91다36307 판결 참조(대법원 1995. 12. 21. 선고 94다26721 전원합의체 판결에 의하여 변경됨).

다음과 같은 다양한 시각으로 임금을 이해하고 있는데, 각 견해의 차이는 결국 “근로의 대가”를 어떻게 이해하는가에 있다.

가. 임금의 개념에 관한 학설⁶⁾

구분	핵심요소	내용
최협의설	쌍무계약상 근로의 대가 중심	- 임금은 근로계약의 쌍무적 견련관계에서, 근로 제공에 대한 반대급부로 지급되는 금품에 한정. - 근로의 제공과 직접적 연계가 없는 은혜적·호의적 금품, 실비변상적 금품(복리후생비, 여비 등)은 임금에서 제외.
포괄설	근로대가성 포괄적 인정	- 복리후생적 급여 등도 근로의 대가로 지급되는 한 임금에 포함. - 가족수당 등 근로시간과 직접 비례하지 않더라도, 실질적으로 근로의 대가로 지급된다면 임금에 포함 - 임금이분설(생활보장적 임금과 근로대가적 임금의 구분)을 부인하면서, 근로제공과 무관하게 근로자의 지위에 근거하여 지급되는 생활보장적 임금은 없고, 생활보장적 임금으로 보이는 것도 실질적으로 사용자가 의도하는 근로를 제공한 것에 대한 대가로서 지급된다고 봄.
원칙적 포섭설	사용자가 지급한 금품은 원칙적으로 임금	- 근로계약에 따라 사용자가 지급한 금품은 원칙적으로 임금으로 간주. - 근로의 대가가 아님을 사용자가 증명해야 함(입증책임 전환). - 임금성 판단은 객관적으로 하며, 계속성·정기성 등은 보조적 판단표지로 기능.
최광의설 (비용설)	사용자의 비용 전반을 임금으로 포섭	- 임금은 근로자와 가족의 생계유지에 필요한 모든 금품(복리후생, 식비, 연금보험료 등)까지 포함. - 민법상 보수와 달리, 노동법상 임금은 사용자의 인건비 전체로 파악.

협의설이 임금을 근로계약의 쌍무적 견련관계에 따라 지급되는 것으로 엄격하게 제한적인 입장이라면, 최광의설(비용설)은 실제 근로자를 사용하면서 사용자가 부담해야 하는 모든 금품은 근로의 대가로 보아야 한다는 입장으로서, 전자는 지나치게 임금의 개념을 협소하게 해석하고, 후자는 지나치게 임금의 개념을 광의로 해석함으로써 사실상 “근로의 대가”로서의 임금을 이해하기에는 적절하지 않다고 생각한다. 포괄설은 근로의 대가성에 대한 실질적 판단을 요구하는 것인데 그 ‘실질성’을 이해하는데 다소 모호함이 있는 한편, 원

5) 박종희, “임금의 개념과 임금제도의 합리적 운영”, 『노동법포럼』, 2023(제58호), 271-273쪽 참조.

6) 박종희, 2023, 271-273쪽 내용을 참조하면서 필자가 정리한 표이다. 각 학설의 구분은 필자가 임의로 작성한 것이고, 원문에서는 각 학설을 주장하고 있는 저자들이 소개되어 있지만 이 글 본문에서는 이를 별도 표시하지 않았다.

칙적 포섭설은 원칙적으로 사용자가 지급한 금품을 임금으로 이해하면서 다만 사용자에게 반증의 가능성을 남겨두는 입장이다. 두 학설이 원론적인 측면에서는 유사하다고 생각한다. 다만 포괄설은 사용자가 지급한 모든 금품을 임금으로 보는 것은 아니고, 근로시간과의 직접비례성을 요구하지는 않지만 근로제공과의 관계를 고려하고 있는 측면에서 원칙적 포섭설과 차이가 있다.⁷⁾ 원칙적 포섭설은 일단 사용자가 근로자에게 지급하는 금품은 원칙적으로 임금이라고 보아야 하는데, 그 이유는 사용자는 근로자와는 근로계약에 따라 근로의 대가로 금품을 공여하지 원칙적으로 다른 금품을 줄 이유가 없기 때문이고, 다만 사용자와 근로자가 다른 명목으로 금품을 주고받는다면 그것이 임금이 아니라는 점은 그것이 임금이 아니라고 주장하는 자가 증명해야 한다고 한다.⁸⁾

한편, 위와 같은 개념적 설정에도 불구하고 결국 “임금이란 무엇인가?”라는 질문에 대해서는 다시 “근로의 대가란 무엇인가?”라는 질문을 남길 수밖에 없다. ‘근로의 대가’로서 임금 지급인지 여부가 객관적으로 분명한 경우라면 문제가 없겠지만, 그렇지 않은 경우에는 근로의 대가로서 임금인지 여부를 판단해야 한다. 그리고 이를 구체적으로 판단하는 기준에 대해서도 다음과 같은 다양한 입장들이 있는 것으로 확인된다.⁹⁾

나. 임금판단기준에 관한 학설¹⁰⁾

구분	내용
① 위계적 판단기준설	• 상위기준 : 근로의 대가성(임금 인정의 최종적·본질적 판단기준) • 하위징표 : 계속성, 정기성, 일률성, 법적 지급의무성 • 하위징표를 충족하더라도 근로대가성이 부인되면 임금성 부정
② 형식적 구성요소와 실질적 구성요소 구분설	• 형식적 구성요소 : 명칭과 관계없이 지급주체인 사용자가 지급하는 일체의 금품 • 실질적 구성요소 : 지급확정성(고정성, 계속성, 정기성, 일률성), 환가가능성 그리고 지배·관리가능성 • 소극적·부정적 요소 : 실비변상성, 손해보상성(재해보상금, 위자료 등), 사회보험성(국민연금, 건강보험 등 공적 급여) • 복리후생금품은 그 취지상 근로의 대가가 인정된다면 임금에 해당 • 성과금은 계속성·정기성을 갖더라도 지급확정성 고정성이 부족한 것으로 봄

7) 포괄설에 해당하는 임종률·김홍영, 「노동법」, 2024, 406쪽의 내용 참조.

8) 최은배, 온주 근로기준법 [제2조] 제1항 제5호 (임금), 2024. 7. 17.

9) 박종희, 2023, 273-275쪽 참조.

10) 박종희, 2023, 273-275쪽 내용을 참조하면서 필자가 정리한 표이다.

구분	내용
③ 지급의무성· 근로대응성 요구설	• 근로의 대가이기 위해서는 “사용자에게 그 지급의무”(지급의무성)가 있어야 하고, 그 금품이 “근로의 대상”(근로대응성)이어야 한다고 봄 • 지급의무성을 먼저 판단기준으로 적용하고 지급의무성이 인정되더라도 근로의 제공이 대응하고 있지 않다면 근로대응성의 결여로 임금성이 부정됨
④ 단계적 구분설	• 1단계에서 해당 금품이 근로의 대가임이 명백하다면 이들에 대해서는 곧바로 임금성을 긍정(객관적 판단요소, prima facie) • 1차적으로 확신되기 어려운 경우에는 정기성·계속성, 사용자의 지급의무 등과 같은 객관적 판단요소를 추출하여 근로의 대가성을 추정 • 주관적 판단요소를 고려하여 유형론적 접근 방법에 따라 임금성을 판단 • 객관적·주관적 판단요소를 모두 고려한 유형론적 접근 방법에 의해 종합적으로 판단했음에도 불구하고 해당 금품이 근로의 대가에 따라 지급된 것임을 인정할 수 없다면 주관적 판단요소에 (단순 사실관계 확인 차원이 아닌) 가치를 부여하여 해당 금품의 임금성을 부정

임금판단기준이 필요한 이유는 어떤 금품의 지급이 ‘근로의 대가’인지 여부가 불분명한 경우이기 때문에, 원칙적으로 이것의 기준으로 ‘근로의 대가’성을 언급하는 것은 큰 의미가 없다. ①위계적 판단기준설의 계속성, 정기성, 일률성, 법적 지급의무성이 하위징표라고 하는데, 그럼에도 불구하고 근로대가성이 부인되면 임금성을 부정해야 한다고 하고 있어서 다소 논리적으로 이해하기 어려운 측면이 있다. ①설을 제외하고는 ②③④의 학설에서 공통적으로 설정하고 있는 임금판단기준은 ‘지급의무성’이다. 사용자는 근로자의 근로제공에 대한 임금지급의무를 갖는다는 것으로부터 도출되는 당연한 조건이다. 이외 다수의 견해가 사용하고 있는 기준은 계속성·정기성인 듯하다. “임금의 객관적 판단지표는 ‘근로의 대가’ 여부이며, 그것만으로 판단이 어렵다면 그 금품 지급의 계속성·정기성·사건 지급의무 존재 여부 등 인자를 끌어들여 임금성을 판단”¹¹⁾할 수밖에 없기 때문이라고 생각한다.

판례는 일단 “사용자가 근로자에게 지급하는 금품이 임금에 해당하려면 먼저 그 금품이 근로의 대상으로 지급되는 것이어야 하므로 비록 그 금품이 계속적·정기적으로 지급된 것이라 하더라도 그것이 근로의 대상으로 지급된 것으로 볼 수 없다면 임금에 해당한다고 할 수 없다.”라는 입장에 서서 “어떤 금품이 근로의 대상으로 지급된 것이냐를 판단함에 있어서는 그 금품지급의무의 발생이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련

11) 최은배, 온주 근로기준법 [제2조] 제1항 제5호 (임금), 2024. 7. 17.

된 것으로 볼 수 있어야 한다”라고 보고 있다. 명시적으로 표현하고 있지는 않지만 임금의 근로대가성 원칙과 함께, 사용자의 지급의무성, 금품의 근로대상성을 근로대가성 판단기준으로 삼고 있는 것으로 정리해 볼 수 있고, 학설 가운데 임금의 개념과 관련하여서는 포괄설, 임금판단기준과 관련하여서는 지급의무성·근로대응성 요구설에 맞닿고 있는 것으로 생각된다.

2. 근로의 대가로서 임금

이 글의 목적은 임금의 개념에 대하여 새로운 견해를 제시하고자 하는 것은 아니기 때문에 기존의 학설과 판례에 비추어 임금을 이해하는 것으로 충분할 수 있기는 하지만, 어떤 금품이 임금인지 여부를 판단함에 있어서 정기성이나 계속성과 같은 요건을 언급하는 것에 대해서 언급할 필요가 있다.¹²⁾ 이것은 임금의 본질을 오해한 것이라고 생각한다.

어떤 금품이 근로자의 근로제공과 함께 정기적이고 계속적으로 지급되고 있다는 것은 그것이 근로의 제공 자체에 대한 대가이거나 또는 밀접한 관련성을 갖고 있는 것으로 일응 추정할 수 있는 근거가 된다. 그러나 이때 정기성이나 계속성은 임금이 지급되는 양상을 표현하는 것일 뿐, 임금의 실질을 판단하는 근거가 될 수는 없다. 일률성과 같은 요건 또한 마찬가지이다. 이러한 형식적 요소들로 임금 해당성 여부를 판단하는 것은 형식이 실질을 결정하는 결과를 초래한다. 마치 근로기준법 제43조에서 규정하고 있는 임금지급방법에 부합하는 것만이 임금에 해당한다고 해석하는 것이나 마찬가지의 결과를 가져올 수 있다. 결국, 임금은 정기적이면서 계속적으로 지급될 수 있지만, 정기적이고 계속적으로 지급되지 않는다고 해서 임금이 아니라고 볼 수는 없다.¹³⁾

물론 정기성, 계속성 등을 임금판단과정에서 언급하는 경우라도 그것을 임금에 대한 절대적 요건으로 보는 것은 아니고 근로제공과 임금지급의 인과관계를 추정하는 ‘정황적 기준’으로 활용해야 함을 의미하는 것이라고 생각할 수 있다. 이러한 요건을 요구하는 입장에

12) 예컨대 대법원 2019. 4. 23. 선고 2014다27807 판결(퇴직금)은 “사용자가 근로자에게 지급하는 금품이 임금에 해당하려면 그 금품이 근로의 대상으로 지급되는 것으로서, 근로자에게 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급에 관하여 단체협약, 취업규칙 등에 의하여 사용자에게 지급의무가 지워져 있어야 한다.”라고 하는 것과 같이 임금해당성 여부가 금품의 계속적·정기적 지급, 사용자의 지급의무에 달려있는 것처럼 표현하는 경우가 있다. 반면 대법원 2002. 5. 31. 선고 2000다18127 판결(임금)에서와 같이 “근로자에게 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급에 관하여 단체협약, 취업규칙 등에 의하여 사용자에게 지급의무가 지워져 있으면 그 명칭 여부를 불문하고 모두 (임금에) 포함되고”와 같이 표현하는 경우도 있다.

13) 다만 근로기준법에 따라 평균임금 또는 통상임금에 따라 임금을 계산할 때 어떤 임금이 평균임금 또는 통상임금 산정의 모수로서 포함되는지는 별도로 검토해야 한다.

서도, 이것이 절대적 기준은 아님을 말하고 있기도 하다. 그럼에도 불구하고 이러한 기준이 지속적으로 언급됨으로써 근로의 대가성 판단은 형식적이고 획일적이게 될 가능성을 갖는 한편, 현실적으로는 이러한 징표를 벗어나는 임금항목을 꾸준히 만들어 냄으로써 임금에 관한 분쟁 양상을 복잡하게 만든다.

한편, “어떤 금품이 근로의 대상으로 지급된 것이냐를 판단함에 있어서는 그 금품지급의 무의 발생이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것으로 볼 수 있어야 한다”라고 말하는 것은 실질적으로 근로의 대가로서 임금을 판단하는데 근로의 대가일 것을 요구한다는 동어반복이다. 또한 어떤 금품지급의무의 발생이 “근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것”이라면 그 자체로(per se) 근로의 대가로서 지급된 임금이라고 밖에는 볼 수 없기 때문이다.

결국 어떤 금품이 임금인지 여부를 판단하는 기준은 근로자의 근로의 제공에 따라 사용자가 지급하였고, 그에 대한 지급의무를 부담하고 있는지 여부에 달려 있고, 결과적으로 근로계약관계 내에서 근로자의 근로제공이 있음에 따라 사용자가 지급한 금품은 모두 임금이라고 추정하는 것이 임금의 의미에 가장 부합하는 해석이라고 생각한다. 그리고 임금이라고 추정된 금품이 임금이 아니라는 것, 즉 근로의 대가로서 지급한 것이 아니라는 것을 사용자가 증명하는데 성공한다면 해당 금품은 임금이 아니라고 볼 것이다(따라서, 임금의 개념에 대한 ‘원칙적 포섭설’에 동의한다).

한편, 임금에 대한 이해의 차이에도 불구하고, 임금은 ‘사후적’인 것이 될 수밖에 없다. 근로의 대가로서 임금을 이해하는 한, ‘근로’가 이루어진 것에 대한 ‘대가’성이 임금의 본질이기 때문이다.

3. 임금의 사전확정 가능성

임금을 근로계약관계 내에서 사용자가 지급한 금품으로 이해하는 경우, 사용자는 근로자의 근로제공에 따라 임금을 지급해야 하는데, 이 글의 목적에 따라 임금이 근로의 제공을 전제로 사전에 확정된다고 볼 수 있을지, 가능하다면 어떤 범위에서 사전확정이 가능할지 검토해 보고자 한다. 다만, 구체적으로 검토하기에 앞서 여기에서 말하고자 하는 ‘임금의 사전확정 가능성’이라는 것이 무엇인지 확인할 필요가 있다.

‘임금의 사전확정 가능성’이란 첫째, 말 그대로 임금이 사전에 확정되어 있다는 것, 특히

임금 총액이 사전에 확정되어 있다는 것을 의미할 수 있다. 구체적인 근로의 양과 질에 상관없이 임금총액이 사전에 확정되어 있음으로써, 근로자의 실질적 근로의 양과 질은 임금과 관계없는 상태가 된다. 둘째, 근로자가 제공할 근로에 대응하여 사용자가 어떤 방식으로 얼마를 지급할 것인지가 계약상 사전에 구조적으로 정해져 있어, 그 계산이 근로 전 또는 근로 제공과 동시에 명확히 예측 가능한 상태를 의미할 수 있다. 따라서 임금 총액은 구체적인 상황에 따라 달라질 수 있지만, 근로자는 근로의 제공에 따라서 자신의 임금이 어느 정도로 결정될 것인지에 대해 사전에 예측할 수 있다는 의미에서 사전확정 가능성의 의미를 발견해 볼 수 있다.

여기에서 먼저 첫 번째 의미로서 임금의 사전확정 가능성이 성립할 수 있을까?

가. 임금 총액의 사전확정 가능성

근로기준법은 근로계약을 체결할 때 임금의 구성항목, 계산방법, 지급방법 등이 근로자에게 서면으로 교부될 것을 요구하고 있다. 따라서 통상 근로계약에서 1 임금지급기당 지급되는 임금의 총액, 해당 임금의 구성항목이나 계산방법, 지급방법 등을 정해둔다. ‘기본급’이라는 것을 미리 약정해두기도 한다. 기본급은 통상적인 근로의 제공을 전제로 지급할 것이 예정된 금액이라고 할 수 있기 때문에, 형식적으로 이해하면 이와 같은 근로계약 체결 과정에서 이미 기본급과 같은 임금은 사전에 확정된다고 말할지도 모르겠다.

그러나 예컨대 근로계약상 임금 총액을 정하고, 해당 총액이 산출되는 구체적 항목을 정해 두었다고 해서 임금이 사전에 확정되었다고 말하기는 어렵다. 근로자가 근로계약에 정해진 근로제공 내용을 이행하게 되면 그에 대한 대가로 해당 임금을 지급할 것이라는 약정이 표시된 것일 뿐이다. 구체적인 근로제공의 내용과 양태, 정도에 따라 1임금지급기당 임금 총액은 달라질 수 있는 바, 근로의 실태(결근이나 조퇴, 지각 등), 근로시간(실근로시간, 연장근로), 근로의 시기(야간근로, 휴일근로), 근로에 대한 평가(성과수당, 업적수당 등), 근로의 방법(출장·외근수당 등), 근로의 환경(유해·위험환경수당 등), 근로의 내용(본 업무 외 추가 업무에 대한 수당 등), 근로의 대상(근로의 대상 종류나 수에 따른 추가수당 등) 등이 임금을 결정하는 요소이다. 이러한 요소들이 임금의 총액을 결정함에 따라 임금의 구성항목, 계산방법, 지급방법 등은 사전에 확정될 수 있지만, 구체적인 임금의 총액은 확정되기 어렵다.

현행 법상 임금의 사전확정성을 요구하는 것으로 보이는 경우가 있다. 바로 통상임금이 다. 통상임금은 “근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정(所定)근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액”이다(근로기준법 시행령 제6조 제1항). 연장·야간·휴일근로에 대한 추가적인 법정수당을 계산하기 위해 요구되는 통상임금은 “지급하기로 정”해졌기 때문에 근로자의 근로제공이 있다는 전제가 있으면 다양한 임금결정요소에도 불구하고 지급되어야 하는 개념이고, 다른 임금을 결정하기 위한 기준이 되므로, 사전에 확정되어 있을 것이 필요하다. 2024년 대법원 전원합의체판결¹⁴⁾에 따라 기존의 통상임금 판단 기준에 사용되었던 정기적·일률성·고정성의 요건 가운데 고정성 요건은 제외하였는데, 특히 재직조건이나 근무일수 조건이 붙어있는 정기상여금이 통상임금에 포함되는지 여부와 관련한 논란의 결과였다. 따라서 현재는 근로기준법 시행령상의 정의규정과 같이 통상임금은 “정기적이고 일률적으로” 지급된 금품으로서 시간단위 산정을 원칙으로 하는데, “그 본질은 근로자가 소정근로시간에 제공하기로 정한 근로의 가치를 평가한 기준임금”이고, “정기성과 일률성은 그 임금이 소정근로의 대가인 임금임을 뒷받침하는 개념적 징표”이다.¹⁵⁾ 이에 따라 “근로자가 소정근로를 온전하게 제공하면 그 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하도록 정해진 임금은 그에 부가된 조건의 존부나 성취 가능성과 관계없이 통상임금에 해당”하므로, [소정근로를 온전하게 제공한다는 조건을 충족했을 때 = 임금을 지급받을 조건을 충족하였을 때], [그 대가로서 = 근로제공의 대가인 임금으로서], 정기적이고 일률적으로 지급되는 것을 통상임금으로 하는 것이다. 따라서 통상임금도, 그것을 어떤 종류의 임금을 포함시켜 어떻게 계산해 지급한다는 계산방법은 확정될 수 있지만(이러한 측면에서 예측가능성이라는 의미에서의 사전확정가능성은 높을 수 있다), 사전에 그 통상임금 액수 자체가 확정되어 있기는 어렵고, 설사 확정을 지어놓는다고 하더라도 구체적인 근로의 제공에 따른 임금은 달라질 수 있다.

다만, 임금의 총액 가운데에서도 일부의 임금은 사전확정될 수 있다고 생각할 수도 있을 듯하다. 임금은 근로시간 등 근로의 양에 비례하는 부분, 업무성과 등 근로의 질에 비례하는 부분, 그리고 근로의 양이나 질과 관계없이 기타 사유로 지급되는 부분으로 구성될 수 있다. 예컨대, 기본급과 법정수당이 근로의 양에 비례하는 부분이라면, 업무평가에 따른 성과급은 근로의 질에 비례하는 부분일 것이다. 이외 다양한 약정 수당 가운데 근로의 양이나

14) 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결, 대법원 2024. 12. 19. 선고 2023다302838 전원합의체 판결.

15) 상동.

질과 관련이 없는 근로대가성 수당이 있을 수 있다. 근로의 양과 질에 직접 대응하는 임금은 사전확정이 어렵지만, 근로의 양이나 질과 관련이 없는 임금은 사전확정이 가능할 수 있다. 실제 가족 상황과 관계없이 근로자들에게 정기적이고 일률적으로 지급되는 가족수당이 여기에 해당할 수 있을 듯하다.

근로의 양과 근로의 질은 사후적으로 평가되어야 한다. 특히 근로의 양에 따른 임금이 사전에 확정될 수 있다고 본다면 이것은 근로조건의 명시 의무, 가산임금제, 통상임금의 정의 및 그것을 기초로 하는 각종 근로채권의 산정 등 근로기준법상 임금·근로시간 규제의 중요한 부분을 무력화시킬 수 있는 제도가 되는 한편,¹⁶⁾ 확정된 임금만큼 요구되는 근로의 양을 근로자에게 강제하게 된다면 강제근로의 위험까지 담고 있는 것이기 때문이다. 또한 근로자가 확정된 임금만큼 근로의 양과 질을 채우지 못한 경우에는 사용자는 과지급된 임금의 반환청구를 할 수 있다고 보아야 하는지 여부도 함께 문제될 수 있다.

결국 임금은 사용자와 근로자 사이의 근로계약에 의하여 정하여지지만, 근로자의 실제 근로시간이나 근무실적 등에 따라 증감·변동될 수 있고, 임금의 지급 여부나 지급액이 구체적인 근로의 질이나 양과 관계없는 조건에 좌우될 수 있다.¹⁷⁾ 결과적으로 일부 근로의 양이나 질에 관계없는 일부 임금의 사전확정은 가능할 수 있지만, 임금 총액의 사전확정성은 기대하기 어렵다.

그렇다면 두 번째 의미에서의 사전확정가능성은 어떠한가?

나. 임금의 예측가능성으로서의 사전확정가능성

엄밀하게 말했을 때 임금의 예측가능성은 임금에 관한 근로기준법제가 요구하고 있는 임금의 요건이라고 볼 수 있다. 임금이 근로의 대가로서 근로의 양과 질 등에 따라 사후적으로 평가되어야 함은 물론이지만, 근로계약상 소정근로시간이 명시되면서 임금의 구성항목·계산방법·지급방법이 정해진다면 임금에 대한 예측가능성은 확보될 수 있는 한편, 이와 함께 임금이 근로시간법제와 연동하여 연장·야간·휴일근로에 대한 법정수당이 지급되도록 하는 것이 근로시간법이 정하고 있는 원칙일 것이기 때문이다. 이를 위해 근로자는 생

16) 강성태, “포괄임금제 성립 여부의 판단 기준 및 노사합의에 의한 통상임금 변경의 효력 — 대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57852 판결”, 『노동법학』, 2010(제33호), 260쪽.

17) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결. 이 판결은 통상임금의 판단기준에 관한 것으로서 대법원 2024. 12. 19. 선고 2023다302838 전원합의체 판결, 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결에 의하여 변경된 통상임금의 ‘고정성’ 요건을 실시한 것이기는 하지만, 본문의 내용은 통상임금에 관한 것이 아니고 더구나 ‘고정성’에 관한 것도 아니다.

계수단으로서 임금을 예측하고, 그에 따라 생활을 계획하거나 영위할 수 있을 것인 바, 이러한 취지에서 근로기준법에서는 근로계약을 체결하는 경우 근로조건의 명시 의무(근로기준법 제17조), 임금지급의 방법(근로기준법 제43조) 등을 규정하고 있다. 이러한 규정은 임금의 예측가능성을 확보하기 위한 수단이라고 볼 수 있다.

그런데 이러한 예측가능성을 임금의 본질적 속성으로 오해할 수는 없다. 임금을 이해하는 과정에서 사용자에게 지급의무성이 존재한다거나, 계속적이고 정기적으로 지급되고 있는지를 판단하는 것은 임금이 지급되는 근거나 방식을 통해 근로의 대가성을 추정하기 위한 자료이다. 위에서 말한 바와 같이 임금은 근로의 대가성이 있는지 여부를 통해 판단되는 것이 원칙이고, 이를 판단하기 어려운 경우에 보조적으로 사용될 수 있는 지표가 사용자의 지급의무성, 계속성이나 정기성 등이라고 보아야 하기 때문이다.

또한 예측가능성 범위 내에 있는 것만이 임금인 것도 아니다. 근로제공의 비정기성, 예외적 사유의 발생 가능성, 근로환경의 변화 가능성 등은 임금의 예측가능성을 저하시키는 요인으로 작동할 수 있는데, 이러한 경우에는 사전확정가능성 또한 낮아지거나 사라지게 될 것이다.

결국, 임금의 예측가능성은 근로제공에 대한 대가로서 임금을 수령하는 근로자의 편익을 보호하기 위해 수반되는 요구사항이라고 할 수는 있지만, 이것이 임금의 사전확정가능성을 의미하는 것은 아니라고 본다. 예측가능하기 때문에 임금의 사전확정이 가능하다고 본다면, 특히 근로기준법 시행령에 따라 정기성과 일률성이 요구되는 통상임금은 사전확정이 가능하다고 말해야 할 것이다. 그러나, 분명히 통상임금은 그 지급에 있어서 예측가능한 범위 내에 존재한다고 말할 수 있지만, 위에서 말한 바와 같이 그 자체가 통상임금의 사전확정가능성을 의미하는 것이라고 보기는 어렵다.

그리고 위와 같이 임금총액의 사전확정 가능성을 부정적으로 보는 한편, 어느 정도 임금의 예측가능성 측면에서의 사전확정 가능성만을 인정할 수 있다면, 포괄임금약정의 성립가능성에 대해서도 재검토를 해볼 필요가 있다. 이하의 III에서 포괄임금약정에 대해 살펴보기로 한다.

Ⅲ. 임금과 포괄임금약정

1. 포괄임금약정의 의미와 종류

판례에 따르면 포괄임금이란 “사용자와 근로자가 기본임금을 미리 정하지 않은 채 법정 수당까지 포함된 금액을 월 급여액이나 일당임금으로 정하거나 기본임금을 미리 정하면서도 법정 제 수당을 구분하지 않은 채 일정액을 법정 제 수당으로 정하여 이를 근로시간 수와 관계없이 지급하는 것”이다. 이러한 설명에 따르면 포괄임금약정은 기본임금과 법정수당을 구분하지 않고 임금을 지급하는 방식의 포괄임금약정(이를 ‘정액급제’¹⁸⁾라고 표현하기도 한다), 기본급은 정해둔 채 법정수당을 구분하지 않고 일정액을 포괄적으로 지급하는 포괄임금약정(이를 ‘정액수당제’¹⁹⁾라고 표현하기도 한다)으로 구분할 수 있다. 이와 같은 포괄임금에 대한 해석에서 보이는 임금의 사전확정 가능성은, 위 II의 3. “임금의 사전확정 가능성의 의미”에서 살펴본 사전확정 가능성 가운데 첫번째 의미인 임금 총액 혹은 부분의 사전확정 가능성을 의미하는 것으로 이해된다. “기본임금을 미리 정하지 않은 채 법정수당까지 포함된 금액을 월 급여액이나 일당임금으로 정”하는 것, “일정액을 법정 제 수당으로 정하여 이를 근로시간 수와 관계없이 지급하는 것”은 결국 근로의 양이나 질과 관계없이 임금 총액(정액급제 포괄임금약정) 또는 부분(법정수당부분=정액수당제 포괄임금약정)의 총액을 미리 정해두고 지급하는 것이기 때문이다.

2. 정액급제 포괄임금약정

“근로시간, 근로형태와 업무의 성질을 고려할 때 근로시간의 산정이 어려운 것으로 인정되는 경우에는 사용자와 근로자 사이에 기본임금을 미리 산정하지 아니한 채 법정수당까지 포함된 금액을 월급여나 일당임금으로 지급하되 이를 근로시간 수에 상관없이 지급하기로 약정하는 내용의 이른바 포괄임금제에 의한 임금 지급계약을 체결하더라도 그것이 달리 근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 유효하다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2002다16958 판

18) 임상민, “포괄임금제의 성립 및 유효요건”, 「인권과 정의」, 2021년 2월호(통권 502호), 100쪽.

19) 상동.

결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결 등 참조).”(대법원 2020. 6. 25. 선고 2015다8803 판결)

➡ ❶ 기본임금과 법정수당을 포함한 정액급제 포괄임금약정

위 법원 판결에 따르면, “근로시간의 산정이 어려운 것으로 인정되는 경우”에, “기본임금을 미리 산정하지 아니한 채 법정수당까지 포함된 금액을 월급여나 일당임금으로 지급하되 이를 근로시간 수에 상관없이 지급하기로 약정하는 내용의 포괄임금제”도 “근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때” 유효하다. 이 판결이 직접 표현하고 있지는 않지만, 법원은 포괄임금약정에 따라 임금총액을 사전에 확정하는 것이 예외적으로나마 가능하다고 보는 입장인 것으로 생각된다. 그런데 이러한 계약이 임금의 본질에 비추어 가능할까?

위에서 언급한 바와 같이, 임금 총액의 사전확정 가능성은 없다고 보아야 한다. 특히 기본급과 법정수당과 같이 근로의 양과 질에 비례하여 지급되는 임금은 사전확정이 불가능하다고 보지 않는다면 근로기준법상 근로시간·휴게·휴일 등의 기준이 형해화될 수 있음은 앞서 말한 바와 같다.

❶과 같은 포괄임금약정은 도급제 임금지급방식을 떠올리게 한다. 근로기준법에서는 “도급이나 그 밖에 이에 준하는 제도로 사용하는 근로자에게 근로시간에 따라 일정액의 임금을 보장”하도록 하고 있다(근로기준법 제47조). 도급제 임금이라고 하더라도 근로시간을 고려해 임금이 보장되어야 한다는 것이다. 여기에서 특수고용노동자로서 계약을 체결하기는 하였지만 근로기준법상 근로자에 해당한다고 판단이 된 도급노동자 퇴직금사건(대법원 2021. 8. 12. 선고 2021다222914 판결)을 상기해보고자 한다.

한 정수기회사에서 정수기 수리 용역계약을 맺고 서비스를 제공하던 도급노동자(이하, ‘특수고용노동자’라고만 표현한다)에 관한 이 사건에서 법원은 이 사건의 특수고용노동자와 정수기회사의 용역계약이 실질상 근로계약으로서, 이 사건의 특수고용노동자는 근로기준법상 근로자임을 인정하였다. 그리고 근로자로 인정된 특수고용노동자가 청구한 퇴직금을 계산하기 위한 평균임금을 구하면서 법원은 용역계약에 따라 “계좌로 입금된 용역수수료 전체를 임금으로 보는 것이 타당하다”라는 입장에 섰다. 그런데 이 사건의 원심(대전지방법원 2021. 2. 18. 선고 2019나117321 판결)은 근로기준법상 근로자라면 당연히 받았을 연차유급휴가 미사용에 대한 보상으로서 연차수당의 권리는 인정하지 않았다(이 부분

은 대법원에서 별도 판단되지 않음에 따라 원심 판시 내용이 그대로 유지된 것으로 볼 수 있다). 도급노동자로서 소송상 근로기준법상 근로자로 인정되기 전에는 근로자가 아니었으므로 연차유급휴가 등을 적립하거나 사용하는 것을 예정할 수 없었을 것이고, 회사의 취업규칙도 적용받을 수 없었으며, 근로자와 같이 근로일을 산정한 후 연차유급휴가권 발생 조건을 충족했는지 여부를 판단하는 것이 불가능했기 때문이다. 이 문제는 근로자로서 퇴직금을 받는다고 했을 때, 도급노동자로서 재직한 근무기간 동안 받은 보수를 임금으로 환산하고, 그 가운데 임금인 부분과 임금이 아닌 부분을 가려내면서 퇴직금 산정에 필요한 평균임금을 계산하기 위한 과정에서 발생하였다.²⁰⁾ 이 사례는 특수고용노동자로서 용역계약을 체결하고 ‘일의 완성’에 대한 대가로서 수수료를 받아 온 경우, 법원에 의해 근로기준법상 근로자로서 인정이 되면서 그가 받아온 보수에 대한 평가 가운데 소정근로일과 근로시간을 특정할 수 없다는 이유로 임금계산으로부터 법정 유급휴가분에 대한 임금이 제외되는 결과를 보여준다.

위 사례를 도급근로자에게 적용시켜 본다면 다음과 같다. 현행 근로기준법에 따라 도급근로에 대한 대가로서 임금총액을 사전에 확정된 후 근로를 제공받았더라도 임금이 근로시간으로 계산될 수 있어야 하는 한편 계산된 근로시간에 기초하여 연장·야간·휴일근로수당에 관한 근로기준법이 적용될 수 있어야 함은 물론이고 연차유급휴가수당에 대해 별도의 고려가 있어야 하며 퇴직금 등 사후적 임금도 근로 중의 임금에 기초하여 산정되어야 한다. 그런데 포괄임금약정에 따라 “근로시간 수에 상관없이” 임금총액이 결정되어 지급된다면 전반적인 근로기준법상 법정수당 및 유급연차휴가수당에 대한 계산을 할 수 없게 된다. 당사자간의 기본급을 포함한 포괄임금약정이 근로시간을 기준으로 적용되는 근로기준법제를 모두 사문화시켜 버리는 결과가 초래되는 것이다. 정액급제 포괄임금약정은 이러한 결과를 허용하는 임금지급방식이다. 특히 근로의 대가로서 임금이 근로의 양 또는 질과 상관없이 결정될 수 있도록 함으로써 임금의 본질을 흐리고, 나아가 근로자인 자를 근로자가 아니게 만들 수 있는 위험도 있다.

근로기준법에서는 ‘근로조건의 명시’(제17조) 가운데 소정근로시간을 정하도록 하고 있

20) 방강수, “비전형 근로자의 소정근로와 근로조건 — 소정근로일 없는 도급근로자의 연차휴가권을 중심으로”, 『법학논총』, 2022(제39집 제2호), 108쪽에서는 엘트웰 정수기 사건 평석 과정에서 “엘트웰 판결에 따르면, 연차휴가권이 없는 근로자가 등장한 셈이다”라고 평가하였는데, 법원의 판단 내용은 연차휴가권이 없다고 보았다고 보다는 특수고용노동자로서 재직한 기간 중 일반 근로자와 같이 연차휴가를 사용하거나 할 수는 없었고 소정근로일 등이 정해지지 않았기 때문에, 연차휴가수당도 퇴직금을 위한 평균임금을 산정하는데 포함되어야 한다는 근로자들의 주장과 관련하여 이를 계산할 수 있는 방법이 없음을 말한 것이라고 보인다.

다. 소정근로시간과 함께 임금의 구성항목·계산방법·지급방법 등은 서면으로 근로자에게 교부할 것도 요구하고 있다. 근로시간과 관련한 근로기준법제는 근로시간이 산정 가능함을 전제한다. 법정수당 또한 마찬가지이다. 그런데 근로시간을 측정할 수 없어 기본임금과 법정수당을 구분하지 않고 총액으로 정할 수 있다고 한다면, 근로시간을 전제로 산정하게 되어 있는 근로기준법 규정은 적용 자체가 형해화되는 결과가 초래된다. 그리고 이러한 결과를 예방하기 위해 만들어진 것이 근로기준법상 근로시간에 대한 특례규정이다. 근로기준법이 예정하고 있는 “근로시간을 산정하기 어려운 경우”는 “근로자가 출장이나 그 밖의 사유로 근로시간의 전부 또는 일부를 사업장 밖에서 근로”하는 경우이고, 또 “업무의 성질에 비추어 업무 수행 방법을 근로자의 재량에 위임할 필요가 있는 업무”와 같은 경우에는 “근로자대표와 서면 합의로 정한 시간을 근로한 것으로” 간주하도록 하고 있는 바(근로기준법 제58조), 이러한 간주 또는 재량근로시간제를 활용할 수 있는 업무가 현재로서는 제한적이어서 이들 법 규정의 개선을 도모할 필요가 있음은 별론으로 하더라도, 근로기준법은 이미 “근로시간을 산정하기 어려운 경우”를 상정하여 간주 내지 재량근로시간제를 규정하고 있으므로 이러한 근로시간에 관한 특례규정을 활용할 수 있었는지, 활용할 수 없었다면 그 이유는 어디에 있었는지를 확인해야 할 필요가 있는 한편, 이와 같이 근로시간을 산정하기 어려운 경우라도 근로자대표와의 서면합의 등을 통해 근로시간을 합리적인 범위로 정한 후 그에 따른 정당한 임금을 지급하도록 한 것이 근로기준법의 취지일 것이다. 특히 간주근로시간제도는 “사업장 안에서 근로”하는 경우라면 근로시간을 산정하기 어렵지 않다고 보고 있다. 이는 사용자의 근로시간관리를 또한 전제한 것이기도 한데, 포괄임금약정이 이루어지는 사업장들에서 말하는 “근로시간의 산정이 어려운 경우”라는 것이 이러한 법의 전제를 벗어난 것인지에 대해서는 다소 의문이 있다.

위와 같은 의문이 정당하다면 ❶의 정액급제 포괄임금약정은 사실상 성립하기가 어렵다고 볼 수밖에 없다. 어떤 방식으로든(실제 근로시간을 ‘진정으로’ 산정하는 것이 어렵더라도) 근로시간을 정하도록 하는 것이 현행 근로기준법의 태도이고, 근로시간에 따라 임금이 지급되는 것이 정당하다는 전제에 서 있는 것이 또한 근로기준법의 임금지급원칙일 것인바, 이러한 원칙을 위반하여 임금 총액을 사전에 포괄적으로 약정하는 것은 불가능하기 때문이다.

3. 정액수당제 포괄임금약정

“근로시간, 근로형태와 업무의 성질을 고려할 때 근로시간의 산정이 어려운 것으로 인정되는 경우에는, 사용자와 근로자 사이에 기본임금을 미리 산정하지 않은 채 법정수당까지 포함된 금액을 월급여액이나 일당임금으로 정하거나 기본임금을 미리 산정하면서도 법정 제 수당을 구분하지 않은 채 일정액을 법정 제 수당으로 정하여 이를 근로시간 수에 상관없이 지급하기로 약정하는 내용의 이른바 포괄임금제에 의한 임금지급계약을 체결하더라도 그것이 달리 근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 유효하다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2002다16958 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결 등 참조)”(대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다56120 판결)

➡ ②기본임금 이외 법정수당만을 대상으로 하는 정액수당제 포괄임금약정

포괄임금약정의 성립가능성이 실질적으로 문제되어야 하는 경우는 위 ②의 경우와 같이 기본급을 정해두고 법정수당만을 포괄적으로 정하는 것을 약정한 경우이다(①의 포괄임금약정은 불가능하다고 보아야 하기 때문이다). 그리고 또한 간주·재량근로시간제와 같은 근로시간 계산 특례규정이 적용되지도 않는 경우이다(이러한 변형근로시간제는 법적으로 허용되고 있는 근로시간계산의 특례적용방식이기 때문이다). 예를 들어, 구체적인 연장근로시간에 따라 연장근로수당을 지급하는 대신, 고정적으로 1주 12시간 한도로 정해진 근로기준법에 따라 12시간을 근로한 것으로 간주하고 고정연장근로수당을 지급하는 것이나, 구체적인 야간근로시간에 따라 야간근로수당을 지급하는 대신, 통상적으로 수행되는 야간근로시간에 기초하여 야간근로수당을 고정적으로 지급하는 방식 등이 여기에 해당한다. 이러한 법정수당들을 모두 포괄적으로 약정하는 경우도 있을 수도 있다(이 글에서는 ①의 포괄임금약정과 구분하기 위해 편의상 ②의 정액수당제 포괄임금약정을 ‘정액수당약정’이라고 한다).

일단 위 II의 3.에서 임금 중 근로의 양이나 질과 관련이 없는 일정한 부분의 임금은 사전에 확정될 수 있다고 판단하였다. 따라서 근로의 양이나 질과 관련이 없는 약정수당 등 임의수당에 대해서는 근로계약 등 노사 당사자간 합의에 따라 근로자에게 불이익이 없는 등의 사정에 기초해 유효하게 포괄임금약정이 체결될 수 있다고 생각한다. 해당 수당의 지급

여부나 방법이 강행법규를 위반하지 않는 범위 내에서 당사자간의 자유로운 합의에 맡겨져 있기 때문이고, 근로시간에 따른 정당한 보상의 문제가 발생하지 않을 수 있기 때문이다.

그런데 실제로는 연장·야간·휴일근로수당에 관한 포괄임금약정 체결이 문제된다. 주로 많이 활용되는 것은 고정연장근로수당이지만,²¹⁾ 야간근로수당이나 휴일근로수당, 나아가 연차유급휴가수당까지 포함하는 경우도 있다. 그리고 이에 대해 기존의 판례는 연차유급휴가수당을 포괄임금약정에 따라 일당 임금이나 매월 일정액에 포함하여 지급하는 것도 가능하고, 이것이 근로자의 연차휴가권을 박탈하는 것은 아니라고 말하고 있다.²²⁾

① 야간·휴일근로수당의 포괄임금약정 포함 가능성 : 여기에서 우선 어떤 법정수당이 정액수당약정에 포함될 수 있는지 확인해 볼 필요가 있다. 법정수당 가운데 연장근로수당은 근로시간의 수, 즉 근로의 양에 비례하여 지급되어야 보상적 임금이지만, 야간근로수당은 언제 근로가 이루어지는가라는 문제로서 야간근로를 통해 침해될 수 있는 근로자의 건강권과 휴식권에 대한 보상적 임금이다. 다만 계산은 근로시간에 비례하게 된다. 그리고 휴일근로수당은 근로자의 휴식권과 관련된 보상적 임금이고, 그 계산은 근로시간에 비례하면서 그것이 1일 8시간을 초과하였는지 여부에 따라 계산방법이 달라진다. 한편, 이러한 연장·야간·휴일근로수당은 정규 근로시간을 벗어난 예외적 근로에 대한 보상으로서, 원칙적 제한, 예외적 허용의 원칙에 따라야 한다. 비록 장시간 근로 국가로서의 지위가 확고한 우리나라이지만, 기본적인 근로시간의 범위를 벗어나는 근로는 당연한 것이 아니고, 어디까지나 근로자의 개별적 동의를 얻어²³⁾ 정당한 보상을 조건으로 예외적으로 이루어질 수 있도록 하는 것이 근로기준법의 태도이다. 정액수당약정은 이러한 기본적인 원리를 벗어나 사전에 포괄적으로 예외적 근로시간의 자유로운 활용을 허용하는 것으로, 그 체결 자체가 근로기준법의 목적과 내용을 벗어나는 위법한 계약의 내용이라고 생각한다. 정액수당약정의

21) 이 때문에 포괄임금약정을 체결한 후 장시간근로를 강요하는 문제, 실제 약정된 연장근로시간보다 더 긴 연장근로를 해야함으로써 발생하는 정당한 보상에 대한 문제 등이 포괄임금약정과 관련하여 발생하여 최근 포괄임금약정을 금지하는 입법안들이 발의되고 있기도 하다.

22) 대법원 2023. 11. 30. 선고 2019다29778 판결 : “연차수당이 근로기준법에서 정한 기간을 근로하였을 때 비로소 발생하는 것이라 할 지라도 당사자 사이에 미리 그러한 소정기간의 근로를 전제로 하여 연차수당을 일당 임금이나 매월 일정액에 포함하여 지급하는 것이 불가능한 것이 아니며, 포괄임금제란 각종 수당의 지급방법에 관한 것으로서 근로자의 연차휴가권의 행사 여부와는 관계가 없으므로 포괄임금제가 근로자의 연차휴가권을 박탈하는 것이라고 할 수 없다(대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결 등 참조).”

23) 야간근로에 대해서는 근로자의 동의를 요구하는 별도 명문의 규정이 없고, 근로기준법은 특별히 근로시간대에 따른 근로를 금지하지는 않고 있기는 하지만, 야간에 이루어지는 근로가 근로자에게 미치는 영향을 고려하는 한편 헌법상 근로권에 기초하여 근로조건법정주의를 정하고 있는 근로기준법의 목적상 야간근로는 당연히 제한됨을 전제로, 예외적으로 야간근로가 이루어지는 경우에는 근로자의 개별적 동의와 야간근로 후 연속된 11시간 이상(탄력적 근로시간에 대한 규제를 준용)의 휴식권을 보장하는 것이 요구된다고 생각한다.

성립가능성을 긍정하는 견해는 “근로자에게 불이익하지 않다면” 이러한 포괄임금약정도 유효하다고 보는데, 이것은 연장·야간·휴일근로라도 정당하게 보상이 되기만 한다면 정액 수당약정이라는 것도 성립할 수 있다는 것을 바탕에 깔고 있는 바 근로시간에 대한 규제의 원리와 법리를 오해한 것이라고 생각한다.

② 연차유급휴가수당의 포괄임금약정 포함 가능성 : 한편, 위에서 확인한 바와 같이 판례는 연차유급휴가수당도 포괄임금약정에 포함될 수 있다고 보고 있는데, 이러한 해석은 연장·야간·휴일근로수당에 대한 오해보다 더 큰 오해가 발생한 결과라고 생각한다. 특히 연차유급휴가수당의 포괄임금약정 포함에 대해서는 많은 비판적 견해가 존재한다.²⁴⁾ 그 비판의 초점은 연차유급휴가수당은 임금산정 기간의 근로 제공을 대상으로 한 것이 아니라는 점, 오히려 직전연도의 근로제공 비율 및 근속연수에 따라 지급되는 후불적 성격의 보상이라는 점, 휴가권이나 그에 따른 휴가권원이나 그에 따른 수당청구권의 유무나 정도(일수나 액수)도 근로자의 청구 여부에 의존한다는 점 등 “다른 법정 수당과는 성격을 달리”한다는 것에 있고, 이러한 입장에 동의한다.

특히 유급휴일근로수당이나 연차유급휴가수당이 포괄임금약정에 포함된다면, 이것은 해당 근로자에게 휴일이나 휴가에 대한 권리를 박탈하는 것이나 마찬가지라고 볼 수 있는 여지가 있는데, 그 이유는 포괄임금약정은 단지 ‘근로시간에 대한 임금의 정도’를 예정한 것이기 때문이다. 즉 근로자가 휴일이나 휴가의 권리를 미리 포기한 것은 아니라는 것이다. 만약 휴일 및 휴가수당을 포함한 포괄임금약정이 근로자의 휴일 내지 휴가의 권리를 미리 포기한 것으로 간주한다면, 포괄임금약정은 근로자에 대한 유불리 문제를 떠나 근로기준법상 자유로운 휴일 및 휴가사용의 권리를 침해한 것으로서 당연 무효라고 볼 것이다.

③ 시간외근로수당의 포괄임금약정 포함 가능성 : 다른 한편으로 시간외근로수당 등의 시간단위 법정수당에 대한 포괄임금약정이 해당 시간만큼의 근로를 미리 예정하는 것이나 마찬가지라고 보기도 어렵다. 다만, 예컨대 고정연장근로수당이 1주 12시간의 연장근로를 예정하고 지급된다면(만약 이러한 연장근로시간을 예정하지 않고 노동조합의 요구 등에

24) 강성태, “포괄임금제의 노동법적 검토”, 「노동법연구」, 2008(제26호) ; 하갑래, “포괄임금제의 내용과 한계”, 「노동법학」, 2009(제29호) ; 김홍영, “포괄임금제 법리의 새로운 검토”, 「성균관법학」, 2011(제23권 제3호) ; 심재진, “포괄임금제의 쟁점과 전망”, 「노동법학」, 2017(제64호) ; 김기선, “포괄임금제와 근로시간의 기록·관리”, 「법과 정책연구」, 2020(제20집 제1호) ; 임상민, 앞의 논문 등. 연차유급휴가수당의 포괄임금약정 포함여부에 대해 부정적인 견해들은 대체로 휴일근로수당의 포함에 대해서도 비판적인 것으로 보인다.

따라 일률적이고 명목적인 연장근로수당수당이 지급된다면, 그것은 법정수당에 해당하는 금품이 아니라고 보아야 할 것임), 근로자는 1주 12시간 내에서 사용자의 요구에 따라 근로를 할 의무가 있다. 이것은 연장근로시간을 미리 정해두지 않고 사용자의 사정에 따라 근로시간을 유동적으로 활용할 수 있도록 하겠다는 의미로 해석될 여지가 있을 것이다. 이것은 근로시간을 미리 정해 근로자들의 생활상 편의를 도모하고자 하는 근로기준법상 근로시간제도의 취지를 위반하는 것이라고 보지 않을 수 없다.

이러한 의미에서 ②와 같은 포괄임금약정도 대체로는 성립하기 어렵다고 볼 수 있는데, 또한 이러한 약정이 왜 활용되고 또 실질적으로 어떤 의미를 갖는지를 따져 물어야 한다고 생각한다. 기본급을 낮추고 각종 수당으로 대체하기 위한 목적을 갖는 정도의 의미인지(그렇다면 왜 기본급을 높이는 것이 아닌, 각종 수당으로 임금을 대체하고자 했는지에 대한 진의를 물어야 할 것임), 아니면 진정으로 근로시간을 산정하는 것이 어려운 상태에서 근로자의 시간외근로 등에 대한 동의를 포괄적으로 해두기 위한 목적이었는지 등과 같은 질문이다. 전자라면 포괄임금약정은 전혀 의미를 둘 수 없을 것이고, 후자라면 근로기준법상 근로시간제도의 취지를 위반하지 않는 범위 내에서 그러한 포괄임금약정이 필요한 정도로 근로시간 산정이 어려웠는지 등을 문제삼을 수 있을 것이다.

결국, 실질적으로 포괄임금약정이라는 것이 진정으로 체결될 수 있는 조건이 성립할 수 있는 경우가 얼마나 있을 것인지 대한 의문이 든다. 이것은 “근로시간의 산정이 어려운” 경우라는 것이 존재하는가에 대한 의문이기도 하다. 사실은 “근로시간의 산정이 까다로운” 경우는 있을 수 있지만, 진정으로 “근로시간의 산정이 어려운” 경우는 거의 없고, 근로기준법상의 간주·재량근로시간도 다만 그 편의를 위한 근거를 제공하고 있을 뿐이라고 생각할 수 있다. 또한, 근로시간과 휴게·휴일에 관한 근로기준법제를 일부 사업과 직종의 근로자에게 적용제외할 수 있도록 한 근로기준법 제63조 또한 근로시간의 운용을 적용제외대상이 아닌 근로자들과 달리할 수 있다는 의미일 뿐, 근로의 대가로서 임금을 근로시간과 관계없이 지급할 수 있다는 의미는 아니라는 것도 함께 유의할 필요가 있다.

Ⅳ. 과·오지급된 임금과 포괄임금약정

1. 포괄임금약정 무효에 따른 임금계산의 문제

사용자에 의한 잘못된 계산이나 위법한 지급방식에 의하여 이미 근로자가 임금을 지급받은 경우, 그 계산의 잘못 내지 위법한 지급방식이 시정됨에 따라 근로자에게 이미 지급된 임금 반환이 문제되는 경우가 있다. 대표적인 사례가 위법한 퇴직금 분할 약정에 따라 근로자가 이미 매월 퇴직금을 포함하여 월급을 수령하였는데 그 퇴직금 분할 약정이 위법한 퇴직금 중간정산이라면 근로자는 이미 지급받은 퇴직금 명목의 임금을 사용자에게 반환하여야 하는지이다. 이 문제에 대해서는 대법원의 전원합의체 판결(대법원 2010. 5. 20. 선고 2007다90760 전원합의체 판결)에서 일단 정리된 바 있다. 대법원 전원합의체판결에서 다수의견은 퇴직금 분할 약정이 무효인 경우 이에 따라 지급한 퇴직금 명목의 금원은 부당이득에 해당하여 사용자에게 부당이득반환채권이 발생하지만 이를 자동채권으로 하여 근로자의 퇴직금 채권과 상계할 수 있고, 다만 민사집행법 제246조 제1항(퇴직금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액을 압류금지채권으로 규정), 민법 제497조(압류금지채권의 채무자는 상계로 채권자에게 대항하지 못한다고 규정)에 따라 상계의 범위는 퇴직금 채권의 2분의 1을 초과하는 부분에 해당하는 금액만 허용된다는 입장을 취하였다. 이에 대해서는 대법관 5인의 별개 및 반대의견이 있었다(이 내용에 대해서는 2. 에서 좀 더 자세하게 살펴본다).

이 글의 Ⅱ에서 임금의 의미를 살핀 후 Ⅲ에서 포괄임금약정에 대해 살펴보았다. 여기에 서 위와 같은 과·오지급된 임금의 반환과 관련한 문제에서 포괄임금약정에 따라 지급된 임금의 과·오 지급성이 문제되는 경우에는 이를 어떻게 해석해야 할 것인지에 대한 의문이 든다. 노사가 체결한 연장·야간·휴일근로와 관련한 포괄임금제 약정을 체결하였는데 그 약정이 위법·무효하게 된 경우 사용자는 실제 근로시간에 따라 연장·야간·휴일근로에 대한 대가를 지급해야 할 것인 바, 이때 만약 기지급된 연장 및 휴일근로수당이 실제의 연장 및 휴일근로시간에 비하여 과다하게 지급되었다면 퇴직금의 경우에서와 마찬가지로 근로자는 이를 부당이득으로서 반환해야 하는 문제가 발생하는데 대한 것이다. 이와 관련하여 기존의 판례에서는 기지급수당이 근로자들의 실제 근로시간을 기준으로 근로기준법에 따라 계산한 법정수당보다 많다면 사용자는 근로자들에게 추가 근로에 대한 임금을 추가로

지급할 의무가 없고, 미달하는 부분이 있다면 그 미달하는 차액을 지급할 의무가 있을 뿐이라고 판단하였다.²⁵⁾

여기에서 먼저 “실제 근로시간을 기준으로 근로기준법에 따라 계산한 법정수당보다 많다면” 사용자는 근로자들에게 추가근로에 대한 임금을 추가로 지급할 의무가 없다고 판단한 것의 의미를 해석해볼 필요가 있다. 근로자들에게 지급된 임금이 법정수당보다 많은 경우, 불법적 중간정산에 따른 퇴직금에 대한 대법원 다수의견과 같이, 근로자는 더 많이 받은 임금을 사용자에게 되돌려주어야 하는 것일까? 아니면 대법원은 이미 연장근로수당 등의 명목으로 받은 임금은 설사 초과지급된 측면이 있더라도 되돌려줄 필요가 없다고 보는 것일까? 퇴직금 판결과는 달리 포괄임금약정의 무효사건에서 대법원은²⁶⁾ ‘부당이득의 반환’과 같은 용어를 사용하지는 않았는데, 이 사안에서 근로자가 법정수당보다 많이 받은 금품은 부당이득에 해당하지 않는 것일까? 다른 한편, 이 근로자가 통상임금이나 평균임금을 산출해야 할 때 기준이 되는 임금은 무엇일까?

예컨대 시간당 1만원을 지급해야 하는 근로자에게 시간당 8천원을 지급하였다면 사용자는 나머지 2천원을 더 지급해야 한다는 것이 대법원의 결론이라면, 만약 사용자가 근로자에게 시간당 1만2천원을 지급하였다면, 사용자는 2천원을 돌려달라고 할 수 있는가 아닌가, 또는 시간당 1만2천원을 이미 지급하였으니 다음의 근로 1시간에 대해서는 8천원만 지급해도 되는가, 두 결론의 이론적 근거는 무엇인가라는 것이 쟁점이 될 듯하다. 그리고 이것은 결국 ‘2천원’의 성격이 관건이 될 것이다.

퇴직금	포괄임금약정에 따른 법정수당
i. 사용자는 법정기준 이상의 퇴직금을 지급해야 한다.	i. 사용자는 연장근로 등에 대하여 법정수당 이상을 지급해야 한다.
ii. 무효인 퇴직금 분할 약정이 있다.	ii. 무효인 포괄임금약정이 있다.
iii. 사용자는 무효인 퇴직금 분할 약정에 기초해 매월 임금(a)에 분할 퇴직금(b)을 포함해 지급하였다.	iii. 사용자는 무효인 포괄임금약정에 기초해 매월 기본급(a)에 연장근로수당 등 각종 수당(b)을 지급하였다.
iv. 근로자는 퇴직금이 포함된 임금(a+b)을 수령하였다.	iv. 근로자는 각종 수당이 포함된 임금(a+b)을 수령하였다.
v. 근로자는 원래 받아야 할 임금(a)보다 많은 금품(a+b)을 받았다.	v. 근로자는 약정된 받아야 할 임금보다 많거나 적은 금품(a+b)을 받았다.

25) 대법원 2023. 7. 27. 선고 2023다221359 판결 등.

26) 대법원 2023. 7. 27. 선고 2023다221359 판결.

이와 관련해 먼저 다수 논의가 진행된 바 있는 무효인 퇴직금 분할약정과 지급된 퇴직금의 성격에 관한 판례와 학설을 먼저 살펴보고, 이 문제를 임금과 포괄임금약정의 의미에 대입시켜보고자 한다.

2. 무효인 퇴직금 분할약정과 지급된 퇴직금의 성격에 관한 판례와 학설

가. 판례

퇴직금이 중간정산이라는 명목으로 매월 월급에 포함되어 지급된 경우, 퇴직금 중간정산이 무효라면 퇴직금 명목으로 매월 월급에 포함되어 지급된 금품은 임금인가 아니면 부당이득인가의 문제가 있다. 특히 민법 제741조는 “법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다.”라고 규정하고 있는 바, 근로자가 이 부당이득을 사용자에게 반환하여야 하는 것인가, 또는 다른 민법상 부당이득에 관한 규정들이 적용되어야 하는가 등에 대한 논쟁이 있다.

대법원 2010. 5. 20 선고 2007다90760 전원합의체 판결에서 다수의견은 위법한 퇴직금 분할 약정을 통해 지급된 퇴직금 명목의 금원은 임금이 아니고, 사용자는 법률상 원인 없이 근로자에게 퇴직금 명목의 금원을 지급함으로써 그에 상응하는 손해를 입은 반면 근로자는 그에 상응하는 이익을 얻은 것이기 때문에 이는 부당이득으로서 사용자에게 반환하는 것이 공평의 견지에서 합당하다는 취지로 말하고 있다.²⁷⁾ 이와 같이 부당이득을 공평의 이념으로부터 찾는 것은 대법원의 일관된 견해인 것으로 보인다.²⁸⁾

그러나 “공평과 정의의 이념”이라는 것은 매우 추상적 개념이어서, 어떤 사안에서 재산

27) 대법원 2010. 5. 20 선고 2007다90760 전원합의체 판결 다수의견의 내용 : “근로관계의 계속 중에 퇴직금 분할 약정에 의하여 월급이나 일당과는 별도로 실질적으로 퇴직금을 미리 지급하기로 한 경우 이는 어디까지나 위 약정이 유효함을 전제로 한 것인바, 그것이 위와 같은 이유로 퇴직금 지급으로서의 효력이 없다면, 사용자는 본래 퇴직금 명목에 해당하는 금원을 지급할 의무가 있었던 것이 아니므로, 위 약정에 의하여 이미 지급한 퇴직금 명목의 금원은 같은 법 제18조 소정의 ‘근로의 대가로 지급하는 임금’에 해당한다고 할 수 없다. 이처럼 사용자가 근로자에게 퇴직금명목의 금원을 실질적으로 지급하였음에도 불구하고 정작 퇴직금 지급으로서의 효력이 인정되지 아니할 뿐만 아니라 같은 법 제18조 소정의 임금 지급으로서의 효력도 인정되지 않는다면, 사용자는 법률상 원인 없이 근로자에게 퇴직금 명목의 금원을 지급함으로써 위 금원 상당의 손해를 입은 반면 근로자는 같은 금액 상당의 이익을 얻은 셈이 되므로, 근로자는 수령한 퇴직금 명목의 금원을 부당이득으로 사용자에게 반환하여야 한다고 보는 것이 공평의 견지에서 합당하다.”

28) “부당이득제도는 이득자의 재산상 이득이 법률상 원인을 결여하는 경우에 공평과 정의의 이념에 근거하여 이득자에게 그 반환의무를 부담시키는 것으로서, 특정한 당사자 사이에서 일정한 재산적 가치의 변동이 생긴 경우에 그것이 일반적·형식적으로는 정당한 것으로 보이지만 그들 사이의 재산적 가치의 변동이 상대적·실질적인 관점에서 법의 다른 이상인 공평의 이념에 반하는 모순이 생기는 경우에 재산적 가치의 취득자에게 가치의 반환을 명함으로써 그와 같은 모순을 해결하려는 제도”라는 것이 일반적인 인식인 것으로 보인다(대법원 2024. 6. 27. 선고 2024다216187 판결).

상 이득이 공평과 정의의 이념에 반하는지 여부는 개별적으로 판단되어야 할 것으로 보이는데, 위 대법원 전원합의체 판결의 다수의견에 대하여 별개 및 반대의견은 위법한 퇴직금 분할 약정에 따라 근로자에게 지급된 금원은 부당이익이 될 수 없다는 취지의 반론을 제기하였다.²⁹⁾

한편, 위 대법원 전원합의체 판결의 다수의견에 의하여 위법한 퇴직금 분할 약정에 따라 근로자에게 지급된 금원은 임금이 아니고, 근로자는 수령한 퇴직금 명목의 금원을 부당이익으로 사용자에게 반환해야 한다는 것이 공평의 이념에 부합한다는 것이 일반적인 판례의 논리이기는 하지만, 사용자가 퇴직금 지급을 면탈하기 위한 의도로 퇴직금 분할 약정의 형식만을 취했거나 하는 경우에는 다수의견이 제시한 법리를 적용할 수 없다고 본 경우도 있다.³⁰⁾ 그리고 사용자와 근로자 사이에 유효한 퇴직금 분할 약정이 존재할 수 있기 위해서는, 퇴직금 분할에 대한 명시적인 합의, 임금과 구별되는 퇴직금 명목 금원의 액수 특정, 근로자에 대한 불이익 여부 등이 고려된다고 본다.³¹⁾

결국 판례는 퇴직금 분할 약정의 성립 가능성을 인정하면서, 그 약정이 위법·무효인 경우에는 지급된 금원의 부당이익성에 기초하여 근로자에게는 반환의무가 있다는 것, 사용자는 이에 기초하여 이를 자동채권으로 하여 근로자에게 실제 지급해야 할 퇴직금채무와 상계할 수 있다고 함으로써, 실질적으로는 퇴직금 분할 약정이 위법·무효인 경우와 그러하지 않은 경우에 동일한 결론을 취하고 있다고 말할 수 있다.

이러한 해석의 방향은 퇴직연금제도 하에서도 유사한 것으로 보인다. 확정기여형 퇴직연금제도 하에서 사용자가 확정기여형 퇴직연금의 부담금을 납입하면서 동액 상당을 근로자에게 지급하여야 할 임금에서 공제한 경우, 해당 확정기여형 퇴직연금제도의 설정이나 사용자의 그러한 부담금 납입행위 자체가 무효는 아니라는 것이다. 그리고 차이에 대한 조

29) 대법원 2010. 5. 20 선고 2007다90760 전원합의체 판결 별개 및 반대의견의 내용 : “퇴직금 분할 약정에 따라 근로자에게 지급되는 금원이 퇴직금일 수는 없고 오로지 임금으로서의 성격을 가질 뿐이므로, 근로자가 이를 지급받는 것은 퇴직금 분할 약정이 포함된 근로계약에 따른 정당한 임금의 수령이지 부당이익이 될 수 없고, 따라서 사용자가 그 반환청구권을 가짐을 전제로 하여 근로자의 최종 퇴직 시에 사용자가 그 반환청구권을 자동채권으로 하고 근로자의 퇴직금청구권을 수동채권으로 한 상계항변이 성립할 여지 또한 없다.”

30) 대법원 2010. 5. 27 선고 2008다9150 판결 참조: “퇴직금 제도를 강행법규로 규정한 입법취지를 감안할 때, 위와 같은 법리는 사용자와 근로자 사이에 실질적인 퇴직금 분할 약정이 존재함을 전제로 하여 비로소 적용할 것인바, 사용자와 근로자가 체결한 당해 약정이 그 실질은 임금을 정한 것에 불과함에도 불구하고 사용자가 퇴직금의 지급을 면탈하기 위하여 퇴직금 분할 약정의 형식만을 취한 것인 경우에는 위와 같은 법리를 적용할 수 없다고 할 것이다. 즉, 사용자와 근로자 사이에 월급이나 일당 등에 퇴직금을 포함시키고 퇴직 시 별도의 퇴직금을 지급하지 않는다는 취지의 합의가 존재할 뿐만 아니라, 임금과 구별되는 퇴직금 명목 금원의 액수가 특정되고, 위 퇴직금 명목 금원을 제외한 임금의 액수 등을 고려할 때 퇴직금 분할 약정을 포함하는 근로계약의 내용이 종전의 근로계약이나 근로기준법 등에 비추어 근로자에게 불이익하지 아니하여야 하는 등, 사용자와 근로자가 임금과 구별하여 추가로 퇴직금 명목으로 일정한 금원을 실질적으로 지급할 것을 약정한 경우에 한하여 위와 같은 법리가 적용된다 할 것이다.”

31) 대법원 2022. 3. 17 선고 2018다244877 판결.

정을 통해 퇴직금액을 채우면 될 뿐, 퇴직연금제도의 효력을 부정하면서 퇴직금제도에 따른 지급 청구 등은 인정되지 않는다고 한다.³²⁾

나. 학설³³⁾

학설은 오지급된 퇴직금에 대한 부당이득반환청구권을 인정하는 견해와 부정하는 견해로 구분된다. 우선, 부당이득반환청구권을 인정하는 경우에는 “대법원전원합의체의 별개 반대의견이나 학계의 일부 견해에서처럼 무효가 되는 부분은 퇴직금으로서 지급하는 것에 대한 합의부분이고, 그러한 금원을 지급한다는 합의는 그대로 유효하기 때문에 부가적으로 지급된 금원은 법적 원인 없이 지급된 부당이득이 아니라 임금으로 보아야 한다는 해석 태도에는 동의하기 어렵다.”라고 말하면서, “무엇보다도 임금으로 보아야 할 법적 근거가 없을 뿐만 아니라 당사자의 의사에 반하기 때문이다. ... 임금과는 별도로 퇴직금 명목으로 부가적으로 정해진 금원을 임금과 함께 지급하였으나, 그러한 약정이 무효로 판단되는 경우에 지급된 금원은 임금의 성격을 지닌다고 볼 수는 없으며, 법적 원인 없이 지급된 부당이득에 해당하는 것으로 판단된다. ... 무효인 퇴직금 분할지급약정에 따라 지급된 퇴직금 명목의 금원은 부당이득으로서 반환청구의 대상이 될 수 있다. ... 임금이 초과지급된 경우에 초과지급된 금원은 임금으로 볼 수 없는 것은 당연하다. ... 퇴직금 명목의 금원의 경우에도 당사자들은 퇴직금으로 지급하고 수령하였으나 법적으로 퇴직금으로 인정되지 않는다는 점에서 다를 바 없다. 따라서 임금이 초과지급된 경우에 상계를 예외적으로 허용하는 법리를 퇴직금 명목으로 지급된 금원에 대한 반환채권에 적용하는 것은 가능하다고 본다.”라고 한다.³⁴⁾

반면, 부당이득반환청구의 대상이 되지 않는다고 보는 견해가 있다. 여기에는 퇴직금지급규정에 위반하여 지급된 퇴직금 명목의 금원은 민법 제746조의 불법원인급여에 해당하여 반환의무가 없다는 견해,³⁵⁾ 부당이득이 된다는 것은 중간정산을 무효로 하여 퇴직금을 보장하려는 퇴직금 제도나 중간정산제의 취지에 배치되는 결과를 초래하는 것이며, 나아가

32) 대법원 2022. 3. 17 선고 2018다244877 판결 참조.

33) 대법원 2010. 5. 20 선고 2007다90760 전원합의체 판결 이후의 학설만을 정리하였다.

34) 하경호, “퇴직금 분할지급약정의 효력과 분할 지급된 금원의 성격”, 「고려법학」, 2011(제63호), 1-35쪽의 내용을 개략적으로 요약함.

35) 유성재, “퇴직금 분할 약정과 부당이득반환 여부”, 「노동법학」, 2011(제39호), 265-308쪽의 내용을 개략적으로 요약함. 단, 여기에서 유성재교수는 퇴직금 중간정산규정의 위반은 민법 제746조의 ‘불법’에 해당하지 않고, 퇴직금 중간정산규정을 위반하여 무효인 퇴직금 분할약정에 따라 지급된 퇴직금 명목의 금원은 임금이 아닌 부당이득으로 보아야 한다고 한다.

법위반자(범죄자)에게 정의를 인정하는 부당한 결론에 이르게 된다는 견해 등이 있다.³⁶⁾ 또한 지급된 금품이 임금인지 아닌지는 다시 근로의 대가성이 있는지를 가지고 평가해야 하고, 분할지급 퇴직금은 앞서 대법원이 임금성을 부인하였던 상여금이나 성과급과는 확연히 다른 성격을 가지고 있음을 이유로 부당이득반환청구를 부정하는 견해가 있다.³⁷⁾

3. 포괄임금약정 하에서 과·오지급된 임금과 근로자의 반환의무

가. 기존 판례의 논리에 따른 추론

우선, 대법원은 사용자가 근로자에게 지급하는 임금에 대해서 근로기준법 제43조가 규정한 임금지급 원칙 중 임금의 전액지급원칙으로부터 출발해 사용자가 근로자에 대하여 갖는 초과지급된 임금반환채권과 근로자의 임금채권 상계를 금지하고 있다. 그러나 계산 착오 등으로 임금이 초과지급된 경우 여러 사정을 살펴 합리적인 경우 초과지급된 임금 반환청구권을 자동채권으로 상계하는 것은 무방하다고 본다.³⁸⁾ 다만 사용자의 일방적인 임금상계는 금지되는데, 그 이유는 임금전액지급원칙의 취지가 사용자의 일방적 임금 공제를 금지하여 근로자에게 임금 전액을 확실하게 지급받게 함으로써 근로자의 경제생활을 위협하지 않도록 하기 위한 것이다. 따라서 임금상계는 근로자의 자유로운 의사에 따라 이루어지는 경우에만 가능하다.³⁹⁾

위와 같은 판례의 논리 하에서 임금성이 논란이 되었던 퇴직금사건을 고려한다면, 위법한 포괄임금제 약정에 의하여 과·오지급된 연장근로수당 등이 임금에 해당하는지 여부를 검토해야 할 듯하다. 퇴직금의 경우에는 원래 근로관계가 종료된 후 지급되어야 하는 것임에도 예외적으로 퇴직금 중간정산이라는 방법이 제한적으로 허용되고 있고, 그럼에도 불구하고 위법한 퇴직금 분할약정에 의해 퇴직금이 매월의 임금에 포함되어 지급됨에 따라 그것의 임금성에 대한 논란이 있었다. 이때 임금성이란 퇴직금의 후불임금적 성격을 부정하는

36) 김희성, “연봉제와 퇴직금 - 월급에 포함된 ‘퇴직금 명목 금원’의 부당이득 성립 여부”, 『노동법학』, 2010(제36호), pp.239-264의 내용을 개략적으로 요약함. 김희성 교수는 「결과적으로 근로계약이 존속하는 동안에 퇴직금 명목으로 지급된 금원에 대하여 퇴직금을 분할하여 미리 지급한 효력을 그대로 인정하는 것과 아무런 차이가 없고, 이는 당초에 다수의견이 퇴직금 분할 약정에 따라 지급된 금원에 퇴직금 지급으로서의 효력을 부정하려는 것과는 모순된다.」는 의견에 동의한다는 것을 밝히고 있다.

37) 전형배, “최근 대법원 퇴직금 판례의 법리 분석”, 『노동법학』, 2013(제48호), 95-130쪽의 내용을 개략적으로 요약함. 전형배교수는 여기에서 분할지급 퇴직금을 사용자에게 반환하도록 하는 것은 사건의 구체적인 경위에 비추어 형평에 부합한다는 논리를 지나치게 강조하여 분할지급 퇴직금의 임금성을 성급하게 부인하였다는 평가를 면하기 어렵다고 평가한다.

38) 대법원 1995. 12. 21 선고 94다26721 전원합의체 판결 등 참조.

39) 대법원 2001. 10. 23 선고 2001다25184 판결 판결 등 참조.

의미가 아니라, 예컨대 월 단위로 임금이 지급되는 월급제 하에서 근로자에게 근로의 대가로 매월 지급되어야 하는 임금의 일부인지의 의미이다. 원래의 퇴직금은 그러한 의무가 있는 금품이 아니기 때문에, 매월 임금에 포함되어 지급된 퇴직금의 임금성이 문제되는 것이다.

그런데, 포괄임금약정에 의하여 연장근로수당 등이 포괄적으로 지급된 경우는 퇴직금의 경우와 다르다. 매월 지급된 퇴직금은 원래라면 퇴직금의 후불임금적 성격에 따라 월 급여에 포함되지 않아야 할 금품이지만, 연장근로수당 등은 원래 지급되었어야 했을 임금이고, 다만 포괄임금약정 등에 따라 어느 정도 지급할 것인지가 결정되는 문제이다. 지급 여부의 문제가 아닌, 지급 정도의 문제라는 것이다. 따라서 포괄임금약정이 유효인지 여부를 떠나, 근로자에게 지급된 각종 수당의 임금성이 문제되지는 않는다. 다만, 근로자에게 지급된 임금의 정도가 원래 지급되어야 했을 임금보다 적은 경우에는 사용자의 임금체불이 문제될 뿐이다. 이것은 애초의 포괄임금약정의 효력과도 상관이 없다. 현재 제한적으로나마 유효한 것으로 받아들여지고 있는 포괄임금약정이라도 그것이 유효하기 위해서는 근로자에게 불리하지 않을 것이 요구되는 바, 근로자와의 합의하에 체결된 포괄임금약정이 결과적으로 근로자가 법정 기준에 따라 지급받았어야 할 임금보다 적은 임금이 연장근로수당 등으로 지급되었다면 거기에서 포괄임금약정은 더 이상 유효하지 않게 되기 때문이다.

문제는 근로자에게 연장근로수당 등이 초과지급되었지만 포괄임금약정이 무효인 경우이다. 포괄임금약정이 유효하다면 근로자가 수행한 연장근로시간을 초과하여 받은 연장근로수당 등의 지급효력에도 문제가 없다. 보다 정확하게는, 초과지급되었는지 여부를 판단하기 어렵다고 말하는 것이 옳을 것이다. 그래야 포괄임금약정이 성립할 수 있기 때문이다. 유효한 포괄임금약정 하에서 합의된 연장근로시간에 근로자의 실제 연장근로시간이 미달하였다고 하더라도, 사용자는 그것을 이유로 근로시간을 다룰 수는 없다.⁴⁰⁾

그러나 포괄임금약정이 위법하여 무효인 경우, 그럼에도 불구하고 만약 사용자가 포괄임금약정이 유효하다고 믿으면서 근로자들에게 무효인 포괄임금약정에 따라 산정된 연장근로시간 등에 기초해 연장근로수당 등을 지급하였는데 실제 수행된 연장근로시간 등에 미치지 못한다면, 사용자로서는 근로자의 실제 연장근로시간이 약정(했다고 생각한) 시간에 미달함을 이유로 근로시간을 다투는 것이 허용될 수 있다. 민법상 “법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때”에는 의사표시를 취소할 수 있기 때문이다(민법 제109호 제1항

40) 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다91046 판결.

본문). 즉 유효하다고 믿은 포괄임금약정에 기초해 임금을 지급하였는데 포괄임금약정이 무효라면, 법률행위의 내용(포괄임금약정에 따른 임금지급)의 중요 부분(임금액)에 착오(무효인 포괄임금약정을 유효하다고 신뢰)가 있는 때에 해당하여 사용자는 연장근로수당 등의 지급을 취소하고, 기지급된 임금의 반환을 청구할 수 있으며, 실제 지급되었어야 할 임금에 대하여 초과지급된 부분의 반환을 요청할 수 있는 것이다. 이것이 사용자의 일방적인 임금상계가 아닌가 하는 의문이 있을 수 있지만, 대법원 판례의 취지에 따르면, 이러한 상계가 “근로자에게 임금 전액을 확실하게 지급 받게 함으로써 근로자의 경제생활을 위협하는 일이 없도록 그 보호를 도모”하고자 하는 임금전액지급원칙을 위반한 것으로 보기는 어려울 것이다.

그러나 법률행위의 착오가 “표의자의 중대한 과실로 인한 때”에는 취소할 수 없다(민법 제109조 제1항 단서). 포괄임금약정이 유효하다고 믿은 것이 사용자의 ‘중대한 과실’에 해당한다면 사용자는 이미 지급된 임금의 반환을 요청할 수 없는 것인데, 판례에 따르면 중대한 과실은 표의자의 직업, 행위의 종류, 목적 등에 비추어 보통 요구되는 주의를 현저히 결여한 것을 의미한다.⁴¹⁾ 위법한 포괄임금약정을 유효하다고 착각한 착오가 사용자의 중대한 과실인지에 대한 판단이 논쟁적일 수 있는데, 임금지급의무가 있는 사용자가 임금지급상 편의를 위해 포괄임금약정을 체결하였음에도 그것이 위법함을 알지 못했던 것을 중대한 과실로 인한 착오라고 보기는 어렵다. 또한 포괄임금약정이 무효라는 것은 이 약정에 대한 노사간 합의가 없었거나, 합의가 있었더라도 포괄임금약정의 성립조건으로서 근로시간 산정의 어려움 등의 사실이 존재하지 않았음을 의미한다. 그런데 사용자가 이것이 위법하여 무효임을 알지 못했다는 이유로 포괄임금약정에 의한 임금지급행위를 취소할 수 있도록 하는 것은 사용자의 불법행위를 사후적으로 승인하는 것과 마찬가지로의 결과를 가져올 것이다.

나. 근로기준법의 확인을 통한 추론

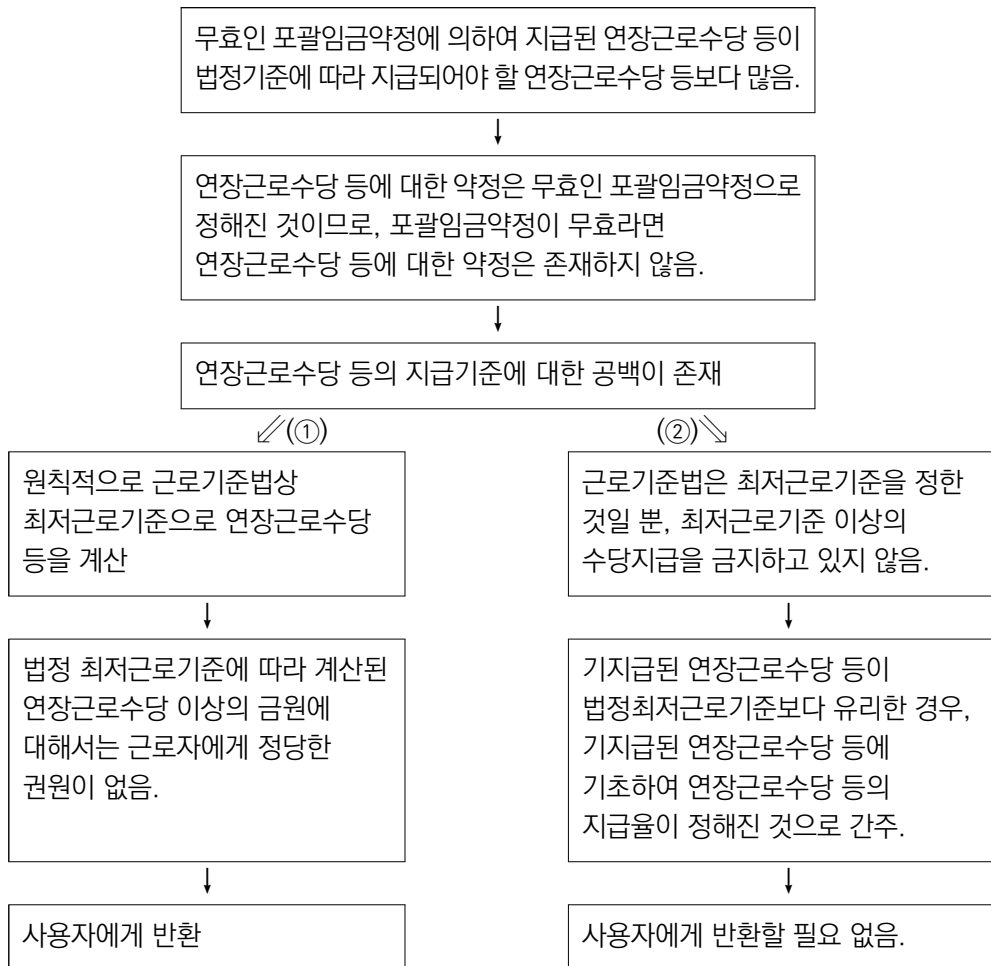
근로기준법 규정에 따라 사용자는 연장·야간 및 휴일근로(8시간 이내)에 대하여 통상임금의 100분의 50 “이상을 가산”하여 근로자에게 지급해야 한다. 포괄임금약정이 무효인 경우, 그래서 근로자의 실근로시간을 측정한 후 연장근로수당 등을 계산해야 하는 경우, 최저근로기준은 통상임금의 100분의 50 이상을 가산해야 한다는 것이지만, 법정 최저근로조건을

41) 대법원 1997. 8. 22 선고 96다26657 판결.

상회하는 노사간의 약정이 별도로 존재한다면 물론 그에 따라 임금을 계산해야 할 것이다.

우선, 포괄임금약정이 무효임에 따라 별도 산정된 실근로시간에 비하여 포괄임금으로 지급된 연장근로수당 등이 적은 경우, 사용자는 법정 최저근로기준에 미치지 못하는 임금을 지급한 것으로서 임금전액의 미지급상태, 즉 임금체불의 상태를 만들게 될 것이다. 여기에서는 과지급된 임금이 존재하지 않으므로 이것은 여기에서의 논의 범주에 포함되는 문제가 아니지만, 근로의 대가로서 임금이 지급되지 않은 것이므로 사용자는 임금체불에 대한 책임을 져야 함은 물론이다.

다음으로, 포괄임금약정이 무효임에 따라 별도 산정된 실근로시간에 비하여 포괄임금으로 지급된 연장근로수당 등이 많은 경우에는 다음과 같이 추론될 수 있다고 본다.



①의 논리가 적용되는 것은 근로기준법 제15조 제1항에 따라 “이 법에서 정하는 기준에 미치지 못하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 한정하여 무효”가 되고, 동조 제2항에 따라 “무효로 된 부분은 이 법에서 정한 기준에 따른다.”는 원칙을 적용한 결과이다. 그러나 이 조항은 근로기준법이 정하는 기준에 미치지 못하는 근로조건을 근로계약으로 정한 경우이다. 따라서 근로기준법보다 높은 근로조건을 정한 근로계약의 내용이 다른 사정에 의하여 무효로 된 경우에는 근로기준법 제15조가 작동하지 못한다. 그렇다면 ②의 해석방법으로 근로계약을 해석해야 한다고 생각한다.

다만, 여기에서 근로자가 선의와 악의에 따라 위 결과가 달라져야 하는가에 대한 문제가 있을 수 있다. 근로자가 포괄임금약정이 무효이거나 성립하지 않았다는 것을 알았다면 기 지급된 연장근로수당 등을 반환해야 하는지의 문제이다. 이것은 다시 민법상 의사표시의 효력에 관한 해석문제로 순환되고, 여기에서는 민법상 진의 아닌 의사표시(제107조)의 효력 문제가 발생한다. 즉, 진의 아닌 의사표시의 상대방인 근로자가 포괄임금약정에 따른 연장근로수당 등의 지급이 사용자의 진의 아님을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 연장근로수당 등의 지급은 무효가 된다. 그렇다면 다시 공백이 된 연장근로수당 등의 계산은 위 ① 또는 ②의 방법으로 이루어져야 할 것인데, 근로기준법에 기초한 해석이라면 역시 ②의 해석방법으로 근로계약 성립을 추론할 수 있을 것이다. 민법상 통정한 허위의 의사표시(제108조)가 문제될 수도 있다. 이때에도 통정한 허위의 의사표시에 따른 연장근로수당 등의 지급은 무효가 되고, 다시 공백이 된 연장근로수당 등의 계산은 위와 달라지지 않는다. 결국 문제는 무효인 포괄임금약정으로 공백상태가 된 임금의 계산방법과 유리한 근로조건에 해석이다.

다른 한편, 임금의 사후적 성격을 고려한다면(Ⅱ.에서 언급한 바와 같다), 이미 지급된 임금은 그 이전에 제공된 근로의 대가이다. 여기에 무효인 포괄임금약정이 존재한다면 임금의 계산과 지급에 대한 합의가 존재하지 않기 때문에 이미 지급된 임금은 이루어진 근로에 대한 대가로서 의미를 갖는 바, 연장근로수당 등이 법정기준보다 높게 산정이 되어 지급되었다 하더라도 그 자체로 연장근로에 대한 대가인 임금으로 간주되어야 한다.

V. 정리하며

이상의 논의를 다음과 같이 정리하면서 이 글을 마치고자 한다.

포괄임금약정은 임금의 본질적 속성, 즉 “근로의 대가로서의 사후적 평가”라는 원칙과 근로기준법상 임금·근로시간 규제의 체계에 비추어 볼 때, 원칙적으로 허용되기 어렵다. 임금은 근로자의 실제 근로시간, 근무실적, 근로의 양과 질 등 사후적으로 평가되는 요소에 따라 지급되어야 하며, 임금총액을 근로계약 체결 시점에서 사전에 확정하는 것은 임금의 본질에 반한다.

포괄임금약정이 제한적으로나마 허용될 수 있는 근거로 판례는 “근로시간 산정이 곤란하고, 근로자에게 불이익이 없으며, 정당성이 인정되는 경우”를 들고 있으나, 실제로는 근로시간 산정이 곤란한 경우에도 간주근로시간제나 재량근로시간제 등 법정 제도가 마련되어 있어 포괄임금약정의 실질적 필요성은 매우 제한적이다. 특히, 연장·야간·휴일근로수당 등 법정수당을 포괄적으로 약정하는 것은 근로시간에 비례해 지급되어야 할 임금의 취지와 근로기준법의 강행규정에 반하므로, 원칙적으로 허용되어서는 안 된다.

나아가, 포괄임금약정이 무효로 판단되는 경우, 이미 지급된 임금이 법정수당을 초과하면 그 초과분의 반환(부당이득) 문제가 발생할 수 있으나, 임금의 대가성과 근로기준법의 취지에 비추어 신중한 해석이 필요하다. 임금의 사후적 성격을 고려할 때, 이미 지급된 임금은 실질적으로 제공된 근로의 대가로 평가되어야 하며, 근로자에게 불리한 결과가 초래되지 않도록 법리적·실무적으로 엄격한 요건 하에 제한적으로만 반환을 인정해야 한다.

종합하면, 포괄임금약정은 임금의 본질과 근로기준법의 체계, 그리고 근로자 보호의 원칙에 비추어 볼 때 그 유효성은 극히 제한적으로만 인정되어야 하며, 근로시간 산정이 곤란한 예외적 상황에서도 법정 근로시간제도의 활용이 우선되어야 한다. 포괄임금약정이 남용될 경우, 임금 및 근로시간 규제의 실질적 의미가 상실될 우려가 크므로, 입법적·해석론적으로 엄격한 제한과 사후적 통제가 필수적일 것이다.

[참고문헌]

- 강성태, “포괄임금제의 노동법적 검토”, 「노동법연구」, 2008(제26호)
- 강성태, “포괄임금제 성립 여부의 판단 기준 및 노사합의에 의한 통상임금 변경의 효력 — 대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57852 판결”, 「노동법학」, 2010(제33호)
- 김기선, “포괄임금제와 근로시간의 기록·관리”, 「법과 정책연구」, 2020(제20집 제1호)
- 김홍영, “포괄임금제 법리의 새로운 검토”, 「성균관법학」, 2011(제23권 제3호)
- 김희성, “연봉제와 퇴직금 - 월급에 포함된 ‘퇴직금 명목 금원’의 부당이득 성립 여부”, 「노동법학」, 2010(제36호)
- 박종희, “임금의 개념과 임금제도의 합리적 운영”, 「노동법포럼」, 2023(제58호)
- 방강수, “비전형 근로자의 소정근로와 근로조건 — 소정근로일 없는 도급근로자의 연차휴가권을 중심으로”, 「법학논총」, 2022(제39집 제2호)
- 심재진, “포괄임금제의 쟁점과 전망”, 「노동법학」, 2017(제64호)
- 유성재, “퇴직금 분할 약정과 부당이득반환 여부”, 「노동법학」, 2011(제39호)
- 임상민, “포괄임금제의 성립 및 유효요건”, 「인권과 정의」, 2021년 2월호(통권 502호)
- 전형배, “최근 대법원 퇴직금 판례의 법리 분석”, 「노동법학」, 2013(제48호)
- 하갑래, “포괄임금제의 내용과 한계”, 「노동법학」, 2009(제29호)
- 하경효, “퇴직금 분할지급약정의 효력과 분할 지급된 금원의 성격”, 「고려법학」, 2011(제63호)
- 임종률·김홍영, 「노동법」, 2025
- 최은배, 온주 근로기준법 [제2조] 제1항 제5호 (임금), 2024. 7. 17.

Abstract

The Concept of Wages: A Critical Review of Employment Contracts Based on All-Inclusive Wage Systems

EunJeong Park

Professor, Korea National Open University, Department of Law

Wages are the monetary compensation paid by an employer in exchange for work performed. While factors such as the obligation to pay, correspondence to work performed, regularity and continuity may serve as supplementary criteria, wages are fundamentally determined by the value of labour under the employment contract. The total amount of wages can vary depending on factors such as the quantity and quality of work, performance at work, and working hours, which makes it difficult to predict the total amount of wages in advance. In this context, an all-inclusive fixed-sum wage agreement renders the relevant provisions of the Labour Standards Act — which are based on calculating wages according to working hours — effectively meaningless. It is also incompatible with the fundamental concept of wages as compensation for work.

In the case of fixed-allowance all-inclusive wage agreements, night work allowances compensate for the potential infringement of workers' health and rest rights due to night work. Similarly, holiday work allowances compensate for infringement of the right to rest. The calculation methods for these allowances vary depending on whether the work exceeds eight hours per day,

www.kci.go.kr

and are proportional to working hours. Therefore, such allowances cannot validly be included in an all-inclusive wage agreement. Although court precedents have recognised that paid annual leave allowances may be included in an all-inclusive wage agreement, this interpretation is an even greater misunderstanding than the misinterpretation regarding overtime, night and holiday work allowances. Furthermore, an all-inclusive wage agreement for hourly statutory allowances, such as overtime pay, could be interpreted as enabling employers to utilise working hours flexibly, at their discretion, without setting predetermined overtime hours. This would violate the intent of the working hour system in the Labour Standards Act, which is designed to ensure predictability and stability in workers' lives.

Finally, if an all-inclusive wage agreement is found to be invalid, statutory allowances must be recalculated based on actual working hours. In such cases, if the wages already paid exceed the statutory allowances, an issue of restitution may arise. Conversely, if the wages fall short, additional payment may be required. However, even in cases where excessive payment is at issue, the amounts already paid should be regarded as compensation for the actual working hours performed by the employee upon the invalidity of the all-inclusive wage agreement.

keywords: Wage, All-Inclusive Wage Agreement, Fixed-Sum Wage System, Fixed-Allowance System, Statutory Allowances, Working Hours

